
Lección I

El derecho del mundo mediterráneo. De la antigüedad a Europa

PID_00230263

Manuel Vial-Dumas

Índice

1. De la tribu a la ciudad.....	5
2. El relato del mudo grecorromano y el primer «nosotros».....	11
3. La ciudadanía romana como definición técnica de un nosotros universal.....	14
3.1. El derecho de los ciudadanos	18
3.2. Los juristas como fuente del derecho, apogeo y decadencia	20
3.2.1. La actividad de los juristas	22
3.2.2. Las fuentes en el periodo posclásico	24
4. La cristianización del Imperio, el desdoblamiento del mundo.....	27
4.1. Nosotros los cristianos	31
4.2. Cristianismo y persona	33
4.3. Cristianización del derecho romano	35
5. La Antigüedad tardía y el desmembramiento de Occidente (s. III-VI d. C.).....	38
5.1. Antecedentes	38
5.2. Dos mundos de un mundo, el desmembramiento	39
5.3. La Antigüedad tardía y el derecho	43
6. El derecho de la Europa latina y la edad de la nostalgia: Alta Edad Media (s. V-X).....	46
7. Qué fue Bizancio.....	53
7.1. La obra de Justiniano	55
7.2. El derecho posjustiniano	57
7.3. El renacimiento de los estudios del derecho	58
Bibliografía.....	63

1. De la tribu a la ciudad

El *Homo* habita la tierra hace más de dos millones y medio de años; nuestra especie, el *Homo sapiens*, hace aproximadamente doscientos mil. Durante la mayor parte de ese extenso periodo de tiempo la organización social predominante ha sido la tribal. Solo en el cuarto milenio antes de Cristo aparecen las primeras civilizaciones o sociedades complejas de las que tengamos noticia. Al contrario de lo que pudiera parecer, este repentino florecer de la civilización no significa que la humanidad diera un salto evolutivo; el *Homo sapiens* como especie no ha experimentado grandes cambios ni físicos ni intelectuales desde que apareció como tal sobre la faz de la tierra. Lo que sucedió es que, en algunas zonas concretas del globo, se formaron grupos humanos que organizaron la vida social de forma sedentaria y procuraron herramientas que permitieron una vida social más compleja. No solo es compleja por la multiplicidad de relaciones, jerarquías o funciones, sino porque estas sociedades abarcan a una cantidad mayor de personas, mucho más amplia que el limitado número de miembros de una tribu.

Quienes estaban fuera de esos círculos sociales siguieron viviendo en estado tribal, incluso hoy existen grupos humanos que permanecen en ese estado. De hecho, si se compara los escasos seis milenios que han transcurrido desde que aparecieron las primeras civilizaciones en Sumer y Mesopotamia con los milenios durante los cuales el hombre ha vivido en estado tribal, parece evidente que el estado de civilización es más bien una excepción en la historia humana, un estado que es más una mentalidad que se adquiere que una condición hacia la que se evoluciona.

Las sociedades tribales, como toda sociedad, presentan varios elementos que permiten la convivencia y justifican la existencia de dicha comunidad. Normalmente existe una visión colectiva de la cosmogénesis que sirve de explicación al mundo natural y dota de sentido sobrenatural a la existencia colectiva e individual. Esta cosmogénesis puede ser particular de una tribu o compartida por muchos otros grupos, igual que la lengua. No obstante, la vida de cada tribu transcurre de manera más o menos independiente. De modo que, además de la cosmovisión compartida o particular, es necesaria una justificación y un fundamento de la cohesión y la organización social del grupo específico. Normalmente el fundamento de dicha sociedad es el parentesco, sea con un antepasado común, muchas veces mítico, sea con los demás miembros de la tribu en un tiempo presente.

En otras palabras, lo que conforma la conciencia de grupo y da sentido a la convivencia es el hecho de estar unidos sus miembros por lazos de parentesco o alianza, normalmente estas últimas constituidas a través del matrimonio.

Es evidente, por tanto, que la amplitud del grupo no puede ser muy extensa. Si aquello que permite a sus miembros reconocerse como tales son elementos como el parentesco y la alianza matrimonial, entonces difícilmente dicho grupo podrá alcanzar grandes dimensiones. En efecto, la vida social tribal suele desarrollarse en pequeños grupos más o menos aislados de unas cincuenta a doscientas personas. Estos grupos tienen una organización más o menos horizontal, sin grandes diferencias entre sus distintos componentes. Suelen ser nómadas o seminómadas y su ocupación principal es la recolección o la caza; muchas tribus alternan entre ambas ocupaciones. Los momentos de contacto con otras tribus sirven para la celebración de ritos y fiestas y, sobre todo, para el intercambio de miembros por causa del matrimonio.

Los antropólogos han estudiado los complejos mecanismos de intercambio, distribución, jerarquización, etc. de estas sociedades. El que se trate de comunidades tribales no significa que dichas reglas sean simples, al contrario, pueden abarcar una considerable cantidad de prescripciones y prohibiciones hasta alcanzar gran detalle. Uno de los ámbitos privilegiados en el derecho de esos pueblos es lógicamente la esfera familiar que, en ese contexto, no es simplemente una sección del derecho privado, sino probablemente el fundamento de la sociedad entera.

Sabemos también que en dichas sociedades normalmente no existe un estado o una organización política lo suficientemente poderosa como para suprimir la venganza privada, de ahí que otra gran preocupación sea conservar la paz social.

Para ello es especialmente útil lo que nosotros llamaríamos **derecho penal**. Se trata de un derecho que, a diferencia del derecho penal impulsado durante la Ilustración¹, es vindicatorio, es decir, busca infligir un sufrimiento en el autor de un delito para conseguir su reincorporación en la sociedad o su definitivo alejamiento. Mediante la aplicación de un castigo se logra la satisfacción de las pretensiones de la sociedad en general y de la víctima en particular, solo así es posible reanudar la convivencia y reincorporar, si es el caso, al que ha delinquido. De otra manera se arriesga la existencia misma de la tribu, pues, al no existir un poder público fuerte o una institución que controle el uso de la fuerza, la venganza de la víctima puede ocasionar una guerra intestina

⁽¹⁾Véase el apartado «La codificación del derecho penal» del módulo «Lección 4: El derecho contemporáneo».

que acabe por disolver al grupo. Máxime si dicho grupo está articulado sobre redes de parentesco y alianzas que obligan a toda la sociedad a tomar partido y auxiliar a los involucrados en el conflicto.

De ahí que las reglas sociales de comunidades tribales puedan llegar a regular circunstancias que llaman la atención del observador contemporáneo: cómo distribuir la carne de un animal que se ha cazado, el orden al comer, la nomenclatura del parentesco, las vestimentas, los matrimonios permitidos y los prohibidos, los castigos, etc. La verdad es que en nuestras sociedades también existen reglas sobre este tipo de asuntos, no obstante son a menudo tan divergentes de aquellas que el ejercicio de la comparación se hace más difícil y menos evidente.

También resulta interesante, sobre todo para el jurista, observar los juicios, los elementos que permiten llegar al conocimiento de los hechos, el valor de los testimonios y las creencias, la necesidad siempre presente de acabar con el conflicto, los castigos que a menudo, por su carácter resocializador, distan mucho de los que se aplican en nuestra sociedad que, paradójicamente, predica con insistencia dicho carácter respecto de las penas que impone. Todas estas cuestiones han sido estudiadas en terreno a través de la observación de tribus contemporáneas que viven aún en dicho estado y también de sociedades de indígenas americanos que, aunque en un estado que no es propiamente tribal, mantienen un sistema jurídico de las características que mencionamos.

No podemos tratar aquí más extensamente las características del derecho de las sociedades tribales. Nos centraremos en entender las consecuencias jurídicas de otro fenómeno: el del paso de una sociedad tribal a una sociedad compleja o civilizada.

Partamos asumiendo que el término **civilizado** no incorpora para nosotros juicios valorativos ni evolucionistas.

Es más, aunque pueda parecer simplista, tal vez sea oportuno, a efectos de esta explicación, tomarlo en un sentido literal, es decir, entender por **civilizadas** a aquellas sociedades que se han establecido en ciudades.

A pesar de que dicha definición podría no ser exacta, es suficiente para plantearnos algunas cuestiones relevantes. Durante doscientos mil años la humanidad no conoció ciudades, ni construcciones monumentales como las que de pronto (mirado desde la lejanía del historiador) aparecieron en Sumer, en Mesopotamia, en Egipto, en la India, por mencionar solo las primeras. No podemos responder aquí a la pregunta sobre el porqué de un cambio tan sustancial, ni por qué entonces, ni en esos lugares. Sí podemos apreciar algunas consecuencias que tuvo semejante ruptura.

Civilizaciones fluviales

Las primeras civilizaciones aparecieron en torno al año 3000 a. C. Son conocidas como civilizaciones fluviales, pues se asentaron en torno a ríos: el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el río Nilo en Egipto, el Indo en la civilización india y el río Amarillo en China.

El primer cambio que se debe mencionar es la radical conversión de la percepción del tiempo.

Las sociedades tribales normalmente tienen una percepción cíclica del tiempo que, de alguna manera, hace menos atractivo el adelanto tecnológico. El hombre civilizado, en algún momento, adquiere una percepción del tiempo que es o se acerca a una percepción lineal, es decir, en la que existe un pasado y un futuro que no necesariamente confluyen en un mismo punto. Entonces parecen cobrar más sentido actividades que se nos antojan hoy casi naturales, como construir viviendas, templos, canales de regadío, etc. Todas ellas son para un futuro distinto del pasado. Pero cambiar la percepción del tiempo no es un paso menor, esos hombres tuvieron que romper con todos los ciclos de la naturaleza que venían siguiendo de forma natural, que determinaban sus desplazamientos, que daban a la naturaleza un carácter sagrado. Esos ciclos determinaban a su vez la visión cíclica del tiempo. En la ruptura de esa percepción está probablemente el comienzo de la gran revolución que significó para esas sociedades el paso de un estado al otro.

En esas sociedades rápidamente se van acumulando una serie de problemas y preguntas que no existían o que al menos no se presentaban de la misma forma antes del paso a un estado de civilización.

Normalmente este estado se asocia a la producción agrícola y al almacenaje de cereales que permiten la supervivencia en periodos de escasez. También a la distribución del trabajo. En las sociedades primitivas las tareas son llevadas a cabo por todos los miembros sin gran distinción; son sociedades, como dijimos, más igualitarias. Asimismo, la diferenciación del trabajo permitirá la especialización, sobre todo en lo que respecta a las artesanías, permitirá también que ese conocimiento especializado dé origen a adelantos técnicos. La distribución de los excedentes de producción determinará la posibilidad de acumular riqueza; en las sociedades primitivas no había hombres ricos. En cambio, la distribución de funciones y del trabajo generará estamentos sociales. Ese mismo excedente puede ser objeto de intercambio y los intercambios generarán el comercio y los medios de cambio. Estas nuevas condiciones favorecerán el incremento demográfico, no solo por la mayor posibilidad de alimentar a la población, sino también por la necesidad de captar mano de obra, normalmente esclava. En estas sociedades aparece también, para algunos de sus miembros, el tiempo para el ocio, las artes, el pensamiento. Y por supuesto será necesaria la aparición de un poder público que pueda ordenar, arbitrar e imponerse en esa sociedad compleja.

El derecho tendrá, pues, que mutar su tradicional carácter y abarcar una serie de campos que antes no se habían abierto. Habrá de servir como herramienta para responder a las preguntas que ya existían, pero que necesitan una res-

puesta diferente, y a otras que se irán planteando por vez primera en la medida que se producen los fenómenos descritos. ¿A quién pertenece el excedente?, ¿cómo se accede a uno u otro estamento?, ¿cómo se comercia?, ¿con quién?, ¿en qué términos?, ¿qué determina el estatus de cada persona?, ¿quiénes son los jueces?, ¿cómo deben decidir los jueces? Y así podríamos seguir enumerando un sinnúmero de preguntas que no dejan de estar vigentes y siguen siendo, muchas de ellas, abordadas por los juristas.

Cuando Aristóteles se refiere al hombre como animal político lo define de esa forma al observar que es el único que vive en ciudades (*polis*) y, por lo tanto, es el único que se plantea todas estas cuestiones. De ahí se desprende que sea social, racional y, podríamos añadir, histórico, pues el hombre es el único animal que necesita de la historia para justificar su presente, su pertenencia a un «nosotros» y proyectar su futuro.

En efecto, entre dichas preguntas que se hace el animal político en particular hay una que nos interesa tratar. Decíamos anteriormente que la sociedad tribal encuentra su factor de cohesión y su fundamento en el parentesco y en las alianzas, sobre todo matrimoniales. Pues bien, una sociedad que habita en ciudades ya no puede dar esa misma respuesta.

En una ciudad, en una sociedad compleja, conviven personas que no tienen vínculos de parentesco entre sí ni se encuentran ligadas a través de alianzas.

¿Cómo justificar y fundamentar la convivencia en común?, ¿la organización social?, ¿las mismas instituciones a las que ha dado lugar el proceso civilizador?

La respuesta a este desafío puede ser caracterizada como simbólica, al menos reviste ese carácter para el observador no partícipe. Es simbólica, pues ya no se basa en vínculos que pueden ser observados y comprobados por sus miembros, sino en un relato.

Aquello que en definitiva permite que los integrantes de sociedades complejas convivan y experimenten empatía unos por otros es un relato que les proporciona un pasado y unos referentes comunes y, sobre todo, un futuro común.

Es así como en estas primeras civilizaciones aparece la **historia**. No hay que confundir esta afirmación con la enarbolada por el positivismo histórico en el siglo XIX y XX. Entonces se decía que la historia comenzaba en los tiempos donde había documentos y monumentos que dejaban signos positivos de las civilizaciones que los habían producido. Normalmente se usaba el hito de la

aparición de la escritura como el origen de la historia; hacia atrás se hablaba de prehistoria. Esta clasificación está hoy obsoleta. No hablamos de historia desde un punto en concreto de la misma, sino que hablamos de la manera de hacer historia que surge con estas primeras civilizaciones. El relato histórico será, pues, un elemento constituyente para esas sociedades, como bien podría afirmarse también respecto de las nuestras.

Es dentro de ese relato que el derecho encuentra justificación.

Ese relato es el que da sentido al derecho, a sus prescripciones y proscripciones, a los procesos y, en fin, a las reglas que ordenan la vida social.

Ese mismo relato es el que dota de una **constitución política** a las sociedades y hace **predecible** el comportamiento de las instituciones. Habitualmente, cuando se habla de una constitución política, los juristas modernos que pertenecen a la tradición jurídica occidental en su vertiente continental² piensan en las constituciones escritas que se promulgaron desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días. Sin embargo, pensar que la constitución política es una cosa tan novedosa sería tan ingenuo como pensar que el derecho mismo también lo es. Lo novedoso es la técnica y la filosofía que hay detrás de esos documentos, no el hecho de que un pueblo tenga una constitución³. Lo importante aquí es hacer hincapié en que dicha constitución, como todo el derecho, se produce en un marco cultural que está determinado por un relato y que, por tanto, se trata de un producto histórico y cultural, no de una simple abstracción. Por eso el derecho debe ser analizado dentro de su marco cultural, pues al fin y al cabo es un producto del mismo.

⁽²⁾ Es decir con exclusión de aquellos que pertenecen a la anglosajona.

⁽³⁾ Volveremos sobre este asunto en el último módulo de estas lecciones.

En lo sucesivo pretendemos estudiar la formación y desarrollo del derecho propio del marco cultural de la civilización cristiano-occidental. Como dicha sociedad no es hija de una comunidad tribal, sino de otra civilización anterior, la grecorromana, deberemos repasar primero el derecho y el marco cultural de dicha civilización.

2. El relato del mudo grecorromano y el primer «nosotros»

Cuando pensamos en la tradición jurídica occidental normalmente fijamos la mirada en Roma. Si se observa bien, se trata una cuestión relativamente excepcional, pues en general, cuando hablamos de las ciencias, las artes y sus orígenes, pensamos en Grecia. Los primeros cultores de la mayoría de las disciplinas del saber, en lo que respecta a la tradición occidental, fueron griegos. Sin embargo, cuando nos referimos al derecho, el mundo heleno suele quedar en un segundo plano. Evidentemente, hay una influencia importante del pensamiento griego en los juristas romanos, ellos conocían a los autores y las escuelas filosóficas. Pero no hubo en Grecia un desarrollo del derecho como una disciplina autónoma. En cambio, mientras que en la gran mayoría de los saberes los romanos bebieron de los logros helenos, en Roma el derecho fue uno de los objetos predilectos de los estudiosos y donde volcaron gran parte de su labor creativa. Pero antes de analizar la creación jurídica romana propiamente dicha, veamos a grandes rasgos cómo es el contexto del Mediterráneo por la época de la expansión romana y cuáles son los instrumentos que dicha expansión utiliza.

Los griegos no formaron nunca, al menos hasta la época de Alejandro Magno (s. IV a. C.), un imperio ni una organización política que superara el ámbito de la *polis*. Ese era para ellos el núcleo esencial de la vida social. De modo que el mundo griego se caracterizaba por ser multipolar, cada ciudad era una organización política autónoma con su propia constitución política, su propio gobierno y su propio derecho. No obstante, tenían conciencia de pertenecer a una comunidad que superaba por mucho a la ciudad. La lengua, la religión y por supuesto un relato común que nace en la obra de Homero constituían los elementos colectivos que permitían la afirmación de un «nosotros» frente al otro: el bárbaro.

Cuando Alejandro se lanza a la conquista de Grecia y, luego, de todo el mundo oriental, quiebra esa tradición ya entonces milenaria y configura un verdadero imperio.

Un imperio que es griego en cuanto se sirve de esos elementos comunes (religión, lengua e historia), pero que supera lo griego al expandirse hacia Oriente con el afán de helenizar el mundo. Su obra, no obstante, fue efímera. Tras su temprana muerte se inaugura el periodo que conocemos como **helenístico**. Políticamente, dicho periodo se caracterizó por el desmembramiento del Imperio Alejandrino en reinos más pequeños que fueron gobernados por sus allegados. Egipto, por ejemplo, será regido por los descendientes de estos griegos

Espíritu común

La guerra de Troya tuvo lugar entre los siglos XIII o XII a. C. Homero compuso la *Ilíada* en el siglo VIII a. C. Los rapsodas declamaban los poemas sobre la guerra por las distintas ciudades independientes que formaban el mundo griego. De esa manera contribuyeron a conservar y fomentar un espíritu común entre ellas.

hasta su definitiva conquista por los romanos. De hecho, la época helenística se agota precisamente por la progresiva expansión romana que termina por conquistar para sí todo el Mediterráneo. Sin embargo, la diáspora griega, sobre todo por el Mediterráneo oriental, proporcionó una unidad cultural que los romanos supieron aprovechar.

Los romanos tuvieron su primer contacto con la cultura griega a través de las *polis* fundadas en la península itálica. Mucho antes de Alejandro, los helenos habían expandido sus redes comerciales por el Mediterráneo, incluso hasta la península ibérica. Habían fundado *polis* que irradiaban el helenismo allí donde estaban situadas. Podría decirse que los romanos fueron un pueblo helenizado. De hecho, cuando tras la batalla de Pidna en el año 168 a. C. los romanos terminan por vencer la resistencia griega y hacerse con sus territorios balcánicos, la conquista militar se ve contrarrestada por una conquista cultural por parte de los griegos. Como hemos dicho, esa conquista ya había empezado en los propios territorios itálicos y se verá intensificada por el contacto con *polis* que se convierten en un polo de atracción para los intelectuales romanos y para toda su aristocracia, que se preciaría desde entonces aprendiendo el griego y, si era posible, estudiando en Atenas u otras ciudades de prestigio. El propio Cicerón era interpelado por Apolonio, un orador griego, que tras comprobar sus dotes retóricas alababa con algún pesar al maestro romano:

«A ti, ¡oh, Cicerón!, te admiro y te alabo, pero me duelo de la suerte de la Grecia, al ver que los únicos bienes y ornamentos que nos habían quedado, la ilustración y la elocuencia, son también por ti ahora trasladados a Roma.»

Plutarco, *Cicerón*, (IV, 24-27).

Más allá de la veracidad de este pasaje, es interesante comprobar que existe entonces conciencia de la apropiación que han obrado los romanos sobre los saberes y las artes de los griegos.

Pero así como existe conciencia de la superioridad de los griegos en estas materias, también son conscientes los romanos de que su mérito es precisamente el de haber formado un aparato institucional estable que permitiera el gobierno del mundo y el de haber desarrollado un derecho que le diera forma.

Es el propio Virgilio quien nos da cuenta de ello. En su *Eneida* narra el periplo del héroe troyano Eneas, que será fundador en el Lacio de la dinastía que engendrará a Rómulo y Remo y dará al fin origen a Roma. Es digno de nota observar cómo los romanos unen su mundo y su cultura con la griega, precisamente, a través de la historia. Es dicho relato el que permite justificar y explicar ese contacto tan íntimo entre los dos pueblos.

Eneas ha perdido a su padre Anquises durante el recorrido que lo llevara desde Troya hasta el Lacio. Por el camino, los dioses conceden a Eneas la gracia de descender al Hades y regresar al mundo de los vivos. Allí, en los infiernos, encuentra a su padre, con quien sostiene una conversación singular. Anquises relata para Eneas el futuro que le espera, le revela cómo su estirpe dará origen a Roma y cómo esa ciudad conquistará el mundo, habla de la monarquía, de la república y del flamante Imperio. En medio de toda esa historia, que es interesante pues muestra la visión de la historia de Roma que tiene el propio Virgilio y Augusto, que fue quien encargó la obra al poeta en el siglo I, hay un pasaje particular que reafirma lo que venimos diciendo. Anquises señala:

«Labrarán otros con más gracia bronce animados
(no lo dudo), sacarán rostros vivos del mármol,
dirán mejor sus discursos, y los caminos del cielo
trazarán con su compás y describirán el orto de los astros:
tú, romano, piensa en gobernar bajo tu poder a los pueblos
(estas serán tus artes), y a la paz ponerle normas,
perdonar a los humildes y abatir a los soberbios.»

Eneida, (VI, 847-854); trad. R. Fontán Barreiro. Madrid: Alianza.

Probablemente, Anquises se refiera a los griegos cuando habla de aquellos otros que lograrán tantos prodigios. Los romanos, en cambio, tienen por arte, según Virgilio, la de ordenar el mundo. Además, en el mismo pasaje señala cómo se hará (o se ha hecho), pues cuando dice «perdonar a los humildes y abatir a los soberbios» lo que hace es describir la herramienta por excelencia de la expansión romana, el *foedus*, es decir, el tratado que concedía un estatus a una ciudad o pueblo dentro del Imperio Romano. Ese estatus estaba a menudo determinado por la forma en que finalmente se habían anexionado, si oponiendo resistencia (soberbios) o de forma pacífica (humildes), en el primer caso las cargas serían mayores y los privilegios menores, al contrario que en el caso de los «humildes». Esta fue la manera de ordenar la incorporación de poblaciones y ciudades enteras a Roma. ¿Pero qué es lo que estaba en juego en esta diferenciación de estatus entre los pueblos? Además de otras cuestiones como las de índole tributaria y militar, uno de los principales elementos de diferenciación era el acceso a la **ciudadanía**. Este elemento será fundamental en la romanización del mundo mediterráneo.

3. La ciudadanía romana como definición técnica de un nosotros universal

Señalamos más arriba que los griegos, hasta la época de Alejandro, nunca constituyeron una entidad política estable que superara el ámbito de la *polis*. La ciudad-estado, como ha sido caracterizada, siempre fue el paradigma de organización política durante la Grecia arcaica y la clásica. También dijimos que, no obstante lo anterior, los griegos siempre se supieron parte de una comunidad mayor, de un «nosotros» que trascendía dicha organización política. Por último, apuntamos que dicha comunidad estaba determinada por la lengua, la religión y una historia compartida. Ese relato común tiene su principio y su pieza principal en la guerra de Troya descrita por Homero. En ella, la mayoría de las *polis* griegas se unen para enfrentar a un enemigo. Pero se trata de una asociación efímera, como otras que vendrán después durante las guerras contra los persas. El Imperio de Alejandro tuvo, en cambio, pretensiones distintas. Su objetivo era unir el mundo bajo un mismo poder e incorporarlo a la luz de la cultura griega. Sin embargo, como también apuntamos ya, ese intento no superó la vida de su impulsor. A la muerte de Alejandro el mundo que conquistara quedó dividido en reinos. Es cierto que la *polis* ya no tendría más la importancia que tuvo antaño, pero también es cierto que esos reinos no heredaron la vocación universal del Imperio de Alejandro.

Roma, en cambio, sí tomó el testigo, y sobre los cimientos de una ciudad, Roma, construyó y ordenó el mundo mediterráneo. La herramienta que usó, además de los tratados que ya mencionamos y que ayudaban a sustentar su expansión militar, fue la ciudadanía. Se trata de un instrumento novedoso que permitió a los pueblos que se anexionaban a Roma la integración relativamente pacífica en su derecho y cultura. Como ya apuntamos, la expansión griega no contó con una institucionalidad estable y universal, menos aún con un dispositivo técnico como la ciudadanía. Integrarse al mundo helénico suponía asumir de alguna manera los elementos que constituían su identidad como pueblo (lengua, religión, historia) y ese proceso naturalmente es difícil. Los romanos, en cambio, crearon una forma de integrarse a la ciudad de Roma que no suponía para el nuevo miembro dejar de ser lo que era antes de convertirse en romano. Para eso hicieron que la pertenencia a la ciudad de Roma no pasara por una asimilación profunda de su cultura, sino por la incorporación a una red de relaciones jurídicas. En otras palabras, hicieron manejable y flexible lo que antes era un arduo proceso de integración a una cultura ajena.

Ser romano se transformó en una categoría técnica. A partir de dicha pertenencia, la asimilación cultural se daba espontáneamente.

En la lógica romana la ciudad no es solo un espacio físico, sino también un espacio inmaterial, un marco cultural. Roma no es solo la urbe, sino una ciudad que está allí donde se extienda su dominio y su derecho. En otras palabras, allí donde haya ciudadanos romanos y se desarrolle la cultura civil a imagen de Roma. Ese espacio cultural es el que se constituye mediante la ciudadanía, que puede ser caracterizada como una red de relaciones interpersonales. El ciudadano se integra en dicha red como quien pasa a formar parte de una asociación de personas.

No se trata, pues, de un vínculo con un territorio o con un estado, sino con otras personas que también forman parte de dicha red de relaciones.

La ciudadanía concedía a quien la poseyera varias posibilidades de materializar esas relaciones interpersonales. El ciudadano podía contraer matrimonio civil (*conubium*), también podía comerciar, adquirir el dominio sobre cosas, obligarse, y obligar, ser causante y heredero aplicando las reglas del derecho civil (*commercium*). Asimismo, podía extender testamento según el derecho civil (*testamentifactio*); es importante señalar aquí que el testamento era también un acto social en el que el testador establecía alianzas y relaciones con otras personas y familias a través de legados. El ciudadano podía entablar acciones y ser actor dentro de un proceso según las reglas del derecho romano (*actiones*). El ciudadano también podía votar en las asambleas de ciudadanos (*suffragium*) y ser elegido como magistrado (*honores*).

Si se observan bien todas estas facultades, se concluye fácilmente que más que derechos son vínculos que pueden establecerse con otros ciudadanos. Quien es ciudadano está en posición de establecer esos lazos con el resto de personas que forman parte de la ciudad (en un sentido inmaterial). Esto no significa que las personas que no poseían la ciudadanía no pudieran casarse, comerciar o establecer otro tipo de relaciones con otros que no fueran ciudadanos o con ciudadanos romanos. Lo que sucede es que dichas relaciones, cuando se dan entre ciudadanos, eran reconocidas y regidas por el derecho de los ciudadanos romanos, es decir, por el *ius civile*.

En definitiva, cuando se es ciudadano se pasa a formar parte de una red de relaciones interpersonales que se rige por el derecho de los romanos. Esa red no excluye a otras; una persona puede formar parte de muchas redes y ser parte de otras ciudades. Por eso ser romano permite ser también otra cosa a la vez, pertenecer a otro círculo, a otro nosotros. Pero la ciudad de Roma es la única que se extiende por todo el mundo mediterráneo y está respaldada por las instituciones públicas del Imperio; sin duda, dicha cualidad constituía una ventaja inestimable. Este carácter técnico de la ciudadanía cambia la noción de «nosotros». Para los griegos, por ejemplo, el otro era quien no hablaba griego, el bárbaro; para los romanos, el otro es quien no es ciudadano.

ius civile

El *ius civile* es, literalmente, el 'derecho de los ciudadanos' (o *quirites*, por eso también se conoce como **derecho quiritarío**). Los romanos entendían que existe un derecho común a todos los hombres y uno que es propio de cada ciudad. El derecho civil romano acabó por convertirse en el derecho de todo el Imperio que, en buena medida, era concebido como una ciudad.

Decíamos que en el estatus que se fijaba para cada ciudad que se integraba a Roma quedaba en alguna medida definido el acceso a la ciudadanía. Así, podía suceder que solo una parte de los habitantes adquiriesen la ciudadanía, o ninguno, o solo aquellos que ocuparan magistraturas romanas. Pero también era posible que la ciudadanía fuera otorgada parcialmente. Al tratarse de un instrumento técnico, la pertenencia a la comunidad de los romanos admite ser fraccionada. De esa manera, podía ocurrir que a los habitantes de ciertas ciudades se les permitiera formar solo alguno o algunos de los vínculos de la red de relaciones que constituye la ciudadanía. Así, por ejemplo, había quienes tenían derecho a comerciar, pero no a casarse o a generar otros de los vínculos descritos arriba. Este era el caso de los latinos, llamados así pues fue un estatus otorgado a los habitantes de la provincia del *Latium* en las primeras etapas de la expansión. Luego, esta condición singular se transformó en un régimen general que se aplicó a otras poblaciones, como por ejemplo a los habitantes de Hispania.

De modo que la ciudadanía fue el principal elemento de romanización del mundo mediterráneo, además de un ejemplo de inteligencia política. Con el tiempo muchas poblaciones fueron adquiriendo la ciudadanía o el estatus de latino que se le acercaba; se trataba de una ventaja que hacía atractivas las buenas relaciones con Roma. El año 212 el emperador Marco Aurelio Antonino Basiano, conocido con el apodo de Caracalla, promulgó el denominado **Edicto de Caracalla** o *Constitutio Antoniniana*. En esta disposición del emperador se concedía la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio, con excepción de los *dediticios* (normalmente se entiende que son aquellos que habían opuesto gran resistencia a la dominación romana). Este edicto marca la cima del proceso de romanización.

Más allá del contenido del mismo o de las razones que llevaron al emperador a promulgarlo (muchos historiadores aducen que la finalidad era recaudatoria), ese proceso llevó a la construcción de un «nosotros» que abarcaba todo el Mediterráneo y que terminó por llevar a todos sus rincones la cultura romana y, por supuesto, la griega.

El Imperio Romano en la época de la promulgación del Edicto de Caracalla



Los propios romanos sabían que su mérito residía en esto, y así lo declamaba Rutilio Claudio Namaciano en el siglo IV:

«Hiciste una patria de gentes diversas,
a los injustos (los que no tienen derecho) aprovechó tu dominio,
pues, ofreciendo a los sometidos compartir tu propio derecho,
una ciudad hiciste de lo que era antes el mundo.»

De reditu suo, (I, 63-66).

Más allá de las batallas que el propio autor quisiera dar con este único poema que de él conservamos, lo importante es observar cómo está ciertamente reflejada en este fragmento la estructura de la expansión.

El dominio del mundo se construye sobre el derecho de los ciudadanos,
por lo tanto lo que hacen los romanos es incorporar a la ciudad de Roma
a todos los pueblos de ese mundo.

De ahí que sostengamos que Roma era sobre todo una realidad inmaterial, una idea. Su materialización no es la urbe romana, sino la ciudadanía; ese instrumento permite extender la ciudad hasta los confines más lejanos y unificar aquello que antes estaba disperso, en definitiva crear un «nosotros» que pueda identificar a todos los habitantes del Imperio.

Como toda creación de este tipo, al final la ciudadanía también es un relato, siempre ideal y nunca realizado del todo. Pero lo cierto es que estos relatos son imprescindibles para la vida en sociedades complejas; de otra manera es difícil experimentar empatía con los demás miembros con quienes no nos unen más vínculos que dicho relato. Pues bien, el primer relato de nuestra

civilización es el de Homero, y el segundo gran relato es esta creación jurídica, muy propia del carácter romano, que permite llevar dentro todo el universo cultural grecolatino y expandirlo por el mundo.

El contexto de la ciudadanía era, como no podía ser de otro modo, la ciudad. El Imperio es también una red de ciudades que se unen con Roma a través de tratados e imitan su estructura institucional.

Sobre ese contexto se extiende la ciudadanía y toda la actividad cultural, incluida la jurídica. Por eso, cuando ese modelo de convivencia social se vea en crisis, como veremos, también la forma de entender el derecho experimentará grandes cambios.

3.1. El derecho de los ciudadanos

Hemos definido la ciudadanía como una red de relaciones personales, lo que nos lleva ahora a analizar el contenido de dichas relaciones. La ciudadanía es un instrumento para conectar y crear relaciones que pueden darse en muchos contextos; lo que hace únicas a las creadas a partir de la ciudadanía romana es que son regidas por un derecho en particular. Lo señala así el propio Rutilio cuando ensalza a Roma por haber compartido su propio derecho con los demás pueblos. En efecto, el *ius civile*, como indica la expresión, es el derecho de los ciudadanos, de ahí que la expansión de la ciudad como entidad inmaterial suponga también la expansión del derecho de esa ciudad. En definitiva, lo que ofrecía la ciudadanía era poder vincularse con otros usando en dichas relaciones el derecho de los ciudadanos, el **derecho romano**.

Los romanos distinguían otros derechos, como el derecho que se utilizaba para las relaciones de ciudadanos con extranjeros o peregrinos, o el derecho de gentes, es decir, el derecho común a todos los pueblos. Pero a nosotros nos interesa abordar aquí la gran obra que justifica que vayamos hasta la Antigüedad a buscar las raíces de nuestro derecho, el **derecho civil romano**. ¿Por qué es tan importante?, ¿qué lo hace distinto al derecho de otros pueblos de la misma época?

En el siglo V a. C. se promulgó la **Ley de las XII Tabas**. Es el texto que marca de alguna manera el momento fundacional de la tradición jurídica romana. Esta ley pretendía hacer públicas las normas fundamentales de convivencia para que fueran aplicadas por igual a patricios y plebeyos. En cierta forma, es un pacto que fija lo que sería el derecho que igualaría a ambos estamentos. Por su importancia se la reconoce como la principal fuente del derecho de los ciudadanos romanos, es el punto de partida del desarrollo que se dará con posterioridad. Pero en sí misma la Ley de las XII Tabas no representa una creación jurídica extraordinaria, sino el punto de partida. La natural ambigüedad del lenguaje y la inabarcable cantidad de casos que no encontraban una solu-

Municipium

La forma de ciudad por excelencia en el Imperio Romano es el *municipium*, es decir, una ciudad que reproduce las formas institucionales de Roma y que permite el acceso paulatino a la ciudadanía a sus habitantes.

Las XII Tabas

Las XII Tabas eran expuestas públicamente para que fueran conocidas por todos los ciudadanos. La tradición señala que, para su redacción, una comisión fue enviada a Atenas para conocer la legislación de Solón.

ción clara en su breve texto favoreció la aparición de un grupo de personas que se ocuparon, poco a poco, de señalar el sentido y el alcance de las reglas contenidas en dicha Ley. No gozaban de ningún respaldo institucional, la legitimidad de sus dictámenes tenía su fuente en el reconocimiento social de su pericia, en la *auctoritas*. Estos personajes son los jurisperitos o jurisprudentes. Es importante resaltar que no se trata de aquellos que simplemente conocen la ley, sino aquellos que saben de derecho, esto es, en su propia concepción, de lo que es bueno y justo. La Ley de las XII Tablas es el primer texto público y pactado que está dotado de legitimidad; a partir de él estos juristas comienzan a desarrollar un pensamiento que dará origen a nuestra tradición jurídica. El texto de la Ley, por lo tanto, da importancia y autoridad a la interpretación que se haga de él, pero son los juristas y su propia *auctoritas* los que sitúan la interpretación como válida.

Pronto, ante la progresiva complejidad de la vida social romana, el escueto texto de la Ley se torna del todo insuficiente. Será la palabra de los juristas la que llene ese vacío, al principio como una interpretación de la Ley, luego como una actividad autónoma. No hay que olvidar que, cuando hablamos del derecho, hablamos básicamente de un conjunto de palabras. Y fue precisamente eso lo que crearon los juristas. Su actividad consistió en amasar esos conceptos y precisar su contenido a partir de la resolución de casos.

Como toda disciplina o arte, el derecho necesitaba de un lenguaje propio, y fueron los juristas quienes lo crearon. Este lenguaje o metalenguaje es la herencia de Roma en lo que al derecho respecta, y lo que hizo distinto su derecho de todos los demás que conociera la cuenca del Mediterráneo hasta entonces.

De modo que el derecho no nació en Roma de la mano del poder público. No al menos el lenguaje del derecho, que es el que nos interesa. Legislaciones comparables a la Ley de las XII Tablas también hubo en otras culturas de la Antigüedad; los propios griegos también las tuvieron. Sin embargo, estos otros pueblos no generaron un lenguaje propio del derecho; por lo tanto, este no se separó ni individualizó respecto de las otras artes liberales. En otros pueblos, el derecho no constituyó una disciplina ni una labor técnica, ni hubo especialistas que cultivaran dicha disciplina. En Roma, en cambio, ese lenguaje propio, requisito de cualquier disciplina autónoma, sí existió y fue creado por los juristas a través de una actividad privada, aunque al fin y al cabo también se pusiera en alguna medida al servicio del poder público. Si se quiere, ese lenguaje jurídico nació como nace un lenguaje artístico que se separa de los otros y genera un estilo o disciplina distinta, o como nace el lenguaje filosófico, es decir, por el acuerdo de un grupo de cultores que son reconocidos como expertos.

La pericia de los juristas era conocer el *ars boni et aequi*, es decir, el arte de lo bueno y equitativo.

¿Cómo se daba en la práctica esta creación?, ¿cómo intervenían los juristas en la vida social? Al fin y al cabo, el derecho necesita de efectividad, y esta actividad libre y artística tenía que conectarse con los instrumentos que finalmente se la proporcionaran.

3.2. Los juristas como fuente del derecho, apogeo y decadencia

Cronologías

Cronología del derecho romano	Cronología política de Roma
Época arcaica (s. VIII-V a. C.)	Monarquía (s. VIII-V a. C.)
Época preclásica (s. V-III a. C.)	República (s. V-I a. C.)
Época clásica (s. III a. C.-III d. C.)	Principado (s. I a. C.-III d. C.)
Época posclásica (s. III-V d. C.)	Dominado (s. III d. C.-V d. C.)

Si intentamos identificar las distintas fuentes del derecho romano veremos cómo, directa o indirectamente, los juristas forman parte de su elaboración o de su funcionamiento en la dinámica jurídica. Como decíamos, los juristas elaboraron el lenguaje jurídico; eso significó nombrar y dar contenido a nuevas realidades que definimos como jurídicas y separarlas de otras como aquellas pertenecientes al ámbito de lo sagrado o de la moral. En dicho proceso se constituye y se reconoce socialmente el grupo de personas que lleva a cabo esta tarea lingüística y técnica, nace de ese modo el oficio de **jurista**.

Desde una perspectiva contemporánea es difícil entender que este grupo de personas sin *potestas*, es decir, sin un poder originario o derivado de las magistraturas, pueda alcanzar una influencia tal que nos permita afirmar que el derecho romano es un derecho de juristas. Decimos que aquello que da legitimidad a la actividad del jurista es la *auctoritas*, es decir, la pericia, el saber socialmente reconocido. El derecho, pues, no se caracterizaba, en la Roma republicana ni en los primeros siglos del Imperio, por ser un derecho emanado del poder público. Es cierto que hay algunas fuentes que emanan de dicho poder, pero en la mayoría de casos, como veremos, son mediadas por los juristas.

A grandes rasgos, podemos distinguir las siguientes fuentes. Nos centramos aquí en la época que denominamos **clásica** (del siglo III a. C. al primer cuarto del siglo III d. C.), pues fue en la que la labor creativa de los juristas alcanzó su máxima expresión, pero mencionamos también las fuentes de periodos anteriores y posteriores que ya hemos tratado o trataremos más adelante:

1) Sin duda, la principal de las fuentes, al menos en términos simbólicos, fue la **Ley de las XII Tablas** a la que ya nos referimos anteriormente. Tal como señalamos, son los juristas quienes definen qué dicen las XII Tablas y amplían su sentido y márgenes hasta dar forma a la disciplina jurídica.

2) **Leyes y plebiscitos.** Las leyes, a diferencia de las que conocemos en el derecho moderno y contemporáneo, no trataban por regla general de asuntos generales o de aquellos que podríamos encajar dentro del cuerpo del *ius civile*. Trataban más bien de asuntos puntuales o resolvían una situación concreta. Sin embargo, en ocasiones sí abordaban asuntos propios del derecho de los ciudadanos. En esos casos es cuando interviene el jurista, quien la interpreta y la integra dentro del acervo del *ius civile*. Sin la intervención del jurista la ley es letra muerta, pues la definición de lo que es derecho, en definitiva, no pertenece a quien elabora la ley, sino al jurista.

3) **Senadoconsultos.** Otro tanto sucede con las respuestas del senado a cuestiones que se le planteaban, normalmente por parte de los propios magistrados que formaban la administración pública romana. También en ocasiones estas respuestas, que solían ser particulares y no vinculadas al *ius civile*, podían entrar en dicho ámbito. En ese caso, también los juristas incorporaban esta fuente mediante la interpretación.

4) **Oraciones imperiales.** Cuando se presentaba una consulta al senado, ya en la época imperial, el príncipe solía dar una recomendación a la asamblea. Dicha recomendación se conoce con el nombre de **oración imperial**. Con el aumento del poder del emperador, sobre todo hacia la época posclásica, dicha oración terminó transformándose en una fuente autónoma. La intervención de los juristas, en este caso, es asimilable a la que tenían respecto de los senadoconsultos.

5) **Edictos jurisdiccionales de los magistrados.** Los magistrados tenían la potestad de promulgar edictos a través de los cuales ejercían su gobierno. Dentro de dichos edictos hay algunos que revisten interés particular para nosotros, pues tienen un contenido jurisdiccional. El más importante en la práctica fue el conocido como **edicto del pretor**. El pretor era un magistrado con amplias facultades de gobierno, y entre ellas, estaba también la potestad jurisdiccional. Al tratarse de una cuestión por entonces ya técnica, precisamente porque los juristas la habían convertido en eso, normalmente el pretor delegaba la elaboración de su edicto sobre materias jurisdiccionales a algún jurista. En dicho edicto el pretor señalaba, entre otras cosas, las acciones que reconocería en su mandato, quiénes podían presentarse en juicio y en general la manera en que se llevaría a cabo la administración de justicia.

El edicto era elaborado por los juristas y mediante su acción se fue actualizando el contenido del derecho civil. No obstante, por emanar este derecho de la potestad de los magistrados y no de la autoridad del jurista ni de fuentes del derecho tradicional como las XII Tablas, el derecho del pretor tenía una

consideración diferente. Como en ocasiones contradecía aquellas reglas tradicionales del derecho de los ciudadanos, sus reglas eran derrotadas por las del *ius civile* si se entablaba el conflicto en un juicio. Por ejemplo, el derecho civil establecía quiénes eran los herederos de una persona muerta; cuando dichas reglas sucesorias eran insuficientes ante la realidad social, el pretor (por lo tanto, el jurista), a través de su edicto, iba introduciendo modificaciones. No obstante estas, en un eventual litigio, no podían prevalecer si se alegaban las reglas del derecho civil. De modo que el derecho del pretor, conocido también como derecho honorario, constituyó un verdadero cuerpo de derecho que se construía sobre el derecho civil, pero que se diferenciaba del mismo en cuanto no podía modificarlo definitivamente. El núcleo del derecho civil, compuesto sobre todo por las XII Tablas y la doctrina de los juristas, permanecía inalcanzable para las reglas emanadas del magistrado. Con todo, fue la fuente que permitió la adecuación del derecho a la realidad social y, por supuesto, fue una fuente labrada por los juristas.

El edicto se dictaba cada año al comienzo de la magistratura para definir la manera en que se desarrollaría la administración de justicia. Poco a poco, el edicto fue estabilizando su contenido, puesto que los magistrados solían repetir el de su antecesor con ligeras modificaciones. Finalmente, se consolidó cuando en época del emperador Adriano (s. II d. C.) se aprobó un texto único y estable del edicto elaborado por el jurista Salvio Juliano que fue conocido como **Edicto Perpetuo**.

6) Constituciones imperiales (*constitutiones principum*). Como estudiaremos más adelante, el poder del príncipe se puso pronto por encima del resto de las magistraturas e instituciones romanas tradicionales y, por lo tanto, algunas de las maneras que tenía el príncipe de expresar su voluntad se convirtieron en fuente del derecho. Veremos cómo en la época posclásica, con la decadencia del modelo de creación libre del derecho por parte de los juristas, esta fuente deviene fundamental y adquirirá el carácter de ley general. A diferencia del papel más bien accesorio que desempeñó la ley en la época clásica, durante la época posclásica las *leges* serán la única fuente del derecho activa, es decir, que es capaz de renovarse y adaptarse a los problemas que se presenten.

3.2.1. La actividad de los juristas

Durante la época clásica los juristas tienen un papel fundamental en la creación del lenguaje jurídico y en la interpretación de aquellos actos de poder que pretenden incorporarse dentro del ámbito del *ius civile*. Por un lado, ellos elaboran muchas de esas reglas, es el caso de los edictos y las constituciones cuya confección a menudo es delegada al jurista. Por otro, la interpretación de todas las fuentes mencionadas es tarea del jurista, pues como cultor del arte es quien está autorizado para decir qué es el derecho y cómo deben entenderse las reglas que emanan del poder público, hayan intervenido o no los juristas en su elaboración.

Para entender por qué es tan relevante la tarea del jurista, debemos describir brevemente cómo se resuelven los asuntos controvertidos. En la resolución de los asuntos jurídicos participan, en la época clásica, básicamente dos personas. Por un lado, el pretor que fija los procedimientos, las acciones que reconocerá en su mandato y, cuando acude ante él una persona, fijará los términos del conflicto y designará a un juez para que determine si se debe absolver o condenar. Esta es evidentemente una visión simplista, pero nos sirve para ilustrar la manera en que el jurista se incorpora al proceso de resolución de controversias jurídicas. Ni el pretor ni el juez son sabedores de derecho, o al menos no se espera que lo sean. El jurista interviene, pues, para resolver las dudas de derecho que se presenten en el juicio, y lo hace a través de respuestas que dirige a los interesados. En ellas, el jurista indica cómo debe resolverse un caso concreto según su pericia.

Recordemos que lo que distingue a los juristas es que cultivan el arte de encontrar la solución buena y equitativa para los casos concretos.

El jurista no emite una respuesta abstracta, teórica o general. El jurista resuelve el caso. Tras esas respuestas es que nosotros podemos descubrir un razonamiento profundo, una serie de principios, escuelas de pensamiento y, sobre todo, un lenguaje común que distingue a quienes forman parte del grupo de los juristas.

La única fuente de legitimidad de este colectivo proviene, recordémoslo, del saber que socialmente le es reconocido; no hay nombramientos ni son investidos de poder alguno. Esas opiniones, respuestas y pensamiento jurídico que emana de los prudentes, de los sabedores del derecho, es la **jurisprudencia**, la principal fuente del derecho en el mundo romano durante la época clásica. No debe confundirse con lo que hoy denominamos como jurisprudencia; en esa época, y en general hasta la época moderna, la jurisprudencia es la opinión de los juristas, no solo las sentencias de los tribunales.

Como puede observarse, la idea de aplicación de la ley es un concepto ajeno a la dinámica jurídica de esta época.

Lo cierto es que es ajena a casi toda la historia de la tradición jurídica occidental al menos hasta el siglo XVIII y XIX. Por eso el derecho depende tanto de los juristas, pues todas las fuentes que señalamos arriba son, en último término, **guías para resolver**, no reglas para aplicar. El jurista recomienda una solución que le parece justa aplicando sus conocimientos técnicos, guiándose por las fuentes mencionadas. No aplica en un acto automático reglas a hechos. En esa actividad, además, el jurista es libre y ajeno a la estructura administrativa de la cosa pública romana.

Tan arraigada estaba la idea de que el derecho era una actividad independiente del poder político que, incluso, esta dinámica resiste los intentos de intervención del poder imperial del propio Augusto y sus inmediatos sucesores. El emperador intentó imponer el llamado *ius respondendi ex auctoritate principis*. Esto quiere decir que el poder del príncipe sirve de respaldo a algunos juristas autorizados por el emperador. Al final, esta medida podía traducirse en que solo estos juristas fueran quienes pudieran dar respuestas a las consultas que se les planteasen en un asunto, o bien, en que su opinión tuviera mayor peso en juicio que la de otros juristas. De esa forma el poder imperial intervenía en la fuente del derecho más importante, la jurisprudencia, que hasta entonces permanecía ajena al poder. Este intento obtuvo escasos resultados por entonces, pero inaugura una ruta que no se detendrá hasta que el poder público termine apoderándose por completo del ámbito del derecho, tradicionalmente reservado a la actividad autónoma de la sociedad y en especial de los juristas.

3.2.2. Las fuentes en el periodo posclásico

Para que la actividad creadora de los juristas decaiga y termine por ser absorbida en el ámbito del poder público habrá que esperar todavía bastante tiempo. Solo en el siglo III d. C., que inaugura la época posclásica, es ostensible que el poder del emperador ha entrado con fuerza a ocupar un lugar preferente en las fuentes del derecho. Desde Constantino en adelante, el emperador dicta sistemáticamente normas generales que caben dentro del *ius civile* y que amplían su tradicional alcance. Lo que antes era excepcional (pues la ley normalmente resolvía cuestiones puntuales y de carácter político) se transforma en algo corriente y de carácter general. Tanto es así que, poco a poco, se irá convirtiendo en la única fuente creadora. Es natural que así fuese, el poder político del emperador también terminó por imponerse a todo poder en Roma. El tradicional equilibrio de poderes de la época republicana se va quebrando hasta que el emperador no tiene contrapeso.

Periodo Dominado

Llamamos a este periodo Dominado (siglo III-V d. C.) y coincide, en buena medida, con el periodo posclásico en la cronología del derecho romano. Su característica principal, desde el punto de vista jurídico, es la preponderancia del emperador como creador del derecho.

Al ser la voluntad del emperador la principal fuente del derecho y ser fijada esta en textos, se hace necesario recopilarlos. De modo que pronto comienzan a reunirse en sendos códigos que los recogen para su manejo en las cortes y el estudio del derecho como el Código Gregoriano, el Hermogeniano y el Teodosiano. Este último tuvo carácter oficial, los dos primeros fueron recopilaciones privadas, dictándose entre finales del siglo III y el siglo V. El **Código Teodosiano** fue promulgado para Oriente el año 438 por Teodosio II, y en el año 439 por Valentiniano III para la parte occidental del Imperio. Se trata de una recopilación de *leges*, probablemente la más importante junto con la obra de Justiniano que estudiaremos más adelante. Si bien no recopila la opinión de los juristas (jurisprudencia o *iura*), recoge una buena parte de la legislación imperial dictada hasta ese momento. Aunque fue elaborado en Oriente y promulgado allí en primer lugar, tuvo una importancia mucho mayor en Occidente. Como

veremos, luego del desmembramiento de la parte occidental del Imperio en el año 476, buena parte del derecho escrito de los pueblos romano-germánicos hundirá sus raíces en el Código Teodosiano.

La literatura jurídica que se denominaba genéricamente como *iura* también fue objeto de recopilación y de obras que sintetizaban su contenido. Sin embargo, la dinámica de creación, propia de la época clásica y que dio origen a esa literatura, cesó. Muestra de ello es la famosa **Ley de citas** (426 d. C.). Dicha disposición limitaba la opinión de los juristas (*iura*), que podía invocarse, es decir, hacerse valer en un juicio. Hasta ese momento podía citarse a cualquier jurista; sin embargo, esta nueva ley determinó que solo podrían citarse cinco juristas célebres: Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino. El juez debía estarse a la opinión de la mayoría de los cinco y, en caso de empate, debía seguir la opinión de Papiniano; en caso de que no prevaleciera ninguna era libre para elegir cualquiera entre las cinco. El motivo que se alegó para esta disposición era evitar la continua falsificación de respuestas de juristas con el objetivo de ganar los litigios. Ninguno de estos juristas que podían ser invocados en juicio estaba vivo, por eso se denominó a los cinco jurisprudentes como el **tribunal de los muertos**.

Lo interesante es ver cómo la limitación de la autoridad de los juristas en juicio, por un lado, y la apropiación de dichas funciones por parte del poder público, por el otro, son signos de un cese de la **actividad creativa** que había caracterizado al derecho romano de juristas. Al mismo tiempo, el conocimiento del derecho decae y se produce una suerte de petrificación del saber jurídico. De modo que a la riqueza y complejidad de las fuentes del derecho romano de la época clásica sigue un sistema mucho más simple.

Las fuentes del periodo posclásico son básicamente las *leges*, es decir, las constituciones imperiales que venían siendo recopiladas, y los *iura*, o sea, la opinión de los juristas, la jurisprudencia.

Pero no la jurisprudencia de los juristas de esa época, sino de los juristas célebres de siglos pasados. De modo que, como hemos advertido ya, al final de la Antigüedad la fuente activa por excelencia es la **legislación imperial**.

Para terminar este apartado, debemos llamar la atención sobre un aspecto de esta nueva forma de creación del derecho. La opinión de los juristas de las épocas pasadas es el *ius vetus*, es decir, el derecho antiguo, y esa antigüedad le da legitimidad. Este fenómeno de valoración de la tradición será la tónica general de la cultura jurídica occidental desde la Antigüedad tardía en adelante. El derecho antiguo gozará de prestigio y legitimidad, pues hay en la percepción que se tiene de él una nostalgia del pasado que permanecerá en el imaginario de los juristas al menos hasta el siglo XIX.

Volveremos a abordar esta nueva impronta⁴ del derecho más adelante; ahora debemos volver sobre el contexto político y espiritual del mundo de la antigüedad tardía.

⁽⁴⁾Véase el apartado «Dos mundos de un mundo, el desmembramiento» del presente módulo.

4. La cristianización del Imperio, el desdoblamiento del mundo

El teatro al que entró en escena el cristianismo era el de un mundo distinto y, en algunos casos, absolutamente opuesto a las enseñanzas de la Iglesia. Había, no obstante, muchas experiencias que de alguna u otra forma coincidían con el mensaje de Cristo. El mundo antiguo había visto brotar un potente sentido de lo individual frente a lo colectivo; asimismo, había concebido ya una moral familiar que se acercaba a la cristiana. También conoció religiones que hablaron de resurrección, como la isiaca. Por último, la filosofía griega, que serviría en muchos casos de sostén para el desarrollo de la doctrina cristiana, se hallaba extendida por el mundo grecorromano. No en vano, en el siglo II, decía san Justino refiriéndose a los pensadores paganos: «Cuanto, pues, de bueno está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos». El teólogo y mártir, conocedor de los clásicos griegos, nos deja testimonio de, por un lado, lo relevante que fue la filosofía griega desde las primeras elaboraciones teológicas de los Padres de la Iglesia y, por otro, de la actitud abierta que caracterizaría al cristianismo primitivo.

En efecto, aquella Iglesia no dudó en integrar todo aquello que ya poseía el mundo pagano y que, cotejado con el mensaje evangélico, era bueno. Por lo demás, esto era necesario, pues el mensaje cristiano no resolvía expresamente muchísimas problemáticas sociales, morales o filosóficas que, mediante el recurso a la cultura existente, se convirtieron en materias sobre las que poco a poco se articuló doctrina. Evidentemente, esta apertura no fue permanente ni igual frente a todas las aportaciones culturales extracristianas. Conocemos episodios de intolerancia a lo precristiano simplemente por el hecho de serlo.

Pero en términos generales los primeros cristianos bebieron con bastante flexibilidad de las ideas de su tiempo en lo que no contradecía los elementos fundamentales de su mensaje.

Para esas concepciones morales compatibles con la Buena Nueva y que ya se encontraban en germen en ese mundo, el cristianismo se convirtió en la vía de entrada al crisol donde se fraguaría el occidente y el oriente cristiano. Lo ajeno, lo opuesto, quedó olvidado en las ruinas de la antigüedad o entró a hurtadillas en la forja. El cristianismo dotó de un sentido trascendental a algunas de las enseñanzas del pensamiento antiguo y a otras tantas concepciones paganas y, con ello, les dio un carácter ahistórico.

Los filósofos precristianos, en su mayoría, no concebían un concepto de verdad absoluta como la cristiana basada en una revelación divina. Ni tampoco, como propuso el cristianismo, que la fe y la sumisión de la razón a la fe pudiera encerrar tal fuerza ordenadora y redentora. Desde la expansión del cristianismo los pensadores no buscan la verdad, pues la verdad ha sido ya revelada, buscan conocerla y desentrañarla; es la edad de la teología.

Esa concepción marcó también el modo en que los primeros cristianos instalarían la nueva religión en el mundo. No se trata de una revolución, porque ellas se caracterizarían por realizar una transformación total y vertiginosa de las instituciones para, así, construir desde arriba un mundo nuevo y un hombre distinto. El cristianismo operó del modo inverso: buscó transformar a los hombres en su tiempo y en su mundo. A esos, a los que se convirtieron, les correspondería la responsabilidad de cambiar las instituciones. La *Epístola a Diogneto*, un testimonio muy antiguo de la vida comunitaria de los primeros cristianos (de fines del siglo II o principios del III) describe así la vida de esas comunidades:

«Los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres. Porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria [...] pero si bien residen en ciudades de griegos o bárbaros, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto al alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía, que ellos nos muestran, es maravillosa [...] Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes; comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos [...] se casan como todos los demás hombres y engendran hijos; pero no se desembarazan de su descendencia. Celebran comidas en común, pero cada uno tiene su esposa. Se hallan en la carne, y, con todo, no viven según la carne.»

Epístola a Diogneto.

De modo que el cristianismo no significó una revuelta, sino todo lo contrario, una conversión profunda del modo de entender el mundo y las instituciones. Un buen ejemplo es el de la esclavitud. El cristianismo, sin pretender derogarla desde el poder, la humanizó y, en fin, la desterró del espíritu de amos y esclavos. La idea del peregrinaje por este mundo en espera de la gloria del más allá destruyó el sentido de la relación del señor y el siervo, porque, en último término, unos y otros son hermanos ante Dios. Este fue el preludio de las manumisiones masivas que presencié la Antigüedad tardía. Obviamente, esto no significó que la igualdad material o formal se presentara en esas sociedades; siempre han existido formas de explotación, de hecho esta fue sustituida rápidamente por otros medios de subyugación. Pero en concreto una de estas formas, la esclavitud, quedó vacía de sentido teórico, al menos por entonces hasta su nueva masificación en la época de la expansión ultramarina europea en la Modernidad.

El cristianismo no buscaba ser una ordenación de la vida terrenal de los hombres. Antes bien, se erigía como su salvación. La nueva religión introduce este contraste en el mundo grecorromano y, con ello, contribuyó finalmente a renovarlo. El mundo antiguo era uno. En el mismo mundo habitan vivos y

muertos, dioses e infiernos. Lo sagrado y lo profano pertenecen a ese mismo mundo y es difícil distinguir una cosa y la otra, y el poder también es el poder de ese mundo y del mismo modo es uno solo. La persona pertenece también solo a un mundo.

El cristianismo desdobra el mundo antiguo, desde entonces existe el mundo del más allá y el más acá y, a partir de ese distingo, se construyen dos mundos paralelos, que conviven, pero que tienen márgenes claros.

Esa división abre un terreno inmenso, al menos en el terreno conceptual, a lo que es relativo y opinable. Lo sagrado se ubica fuera de este mundo, en el más allá, por lo tanto lo del más acá no es nunca absoluto ni definitivo; los poderes, las dignidades, las desigualdades quedan finalmente relativizadas por el otro mundo del que este depende. Lo temporal es por naturaleza profano, salvo allí donde se conecta con lo espiritual y lo sagrado. Solo lo sagrado es perenne e inmodificable, todo lo demás queda en cierta manera abierto al arbitrio del hombre.

Desde temprano, la filosofía cristiana entendió que además del poder temporal, es decir, del poder de este mundo, pasajero y caduco, existía el poder espiritual. Esta concepción se encuentra presente ya en los primeros pensadores cristianos y, cuando la Iglesia alcanza una fortaleza institucional para mirarse de igual a igual con el Imperio, aparecen manifestaciones de esta dualidad.

En efecto, después de largas persecuciones, en el año 311 un edicto de Galeerio cesó las medidas contra los cristianos; sin embargo, Maximiano rehusó su aplicación en la región bajo su administración (Sicilia, Siria y Egipto), donde la persecución duraría hasta el año 313. Cuando Constantino se convirtió en la cabeza indiscutida del Imperio en 312, el principio de reconocimiento del cristianismo fue definitivamente aceptado en el Edicto de Milán (313). A partir de entonces, la Iglesia pasó rápidamente de tolerada a favorecida por el poder imperial, el mismo Constantino le dona tierras y hace construir una basílica en Roma sobre la tumba de san Pedro. Asimismo, una serie de privilegios jurídicos y sociales gratificaron a la Iglesia. A partir de entonces las costumbres cristianas acaban de difundirse por el Imperio. Graciano renuncia al título *pontifex maximus*, título que haría propio el papa y que pasaría a ser su denominación habitual. El año 380 Teodosio señaló al cristianismo como religión oficial. En adelante la situación se invierte, el paganismo es atacado y los templos son cerrados, confiscados o destruidos. Al mismo tiempo se intensifican las pretensiones imperiales de intervenir en asuntos eclesiásticos o el llamado **cesaropapismo**.

Ante esa pretensión, el papa Gelasio I reacciona y, siguiendo las propias enseñanzas de Cristo –dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios–, interpela al emperador Anastasio con una carta en la que señala que son dos

los rectores del mundo: la autoridad sagrada de los pontífices y la *potestas regia* de los emperadores. El principio no es novedoso, ya lo había señalado san Agustín y también san Jerónimo al decir que «unas son las leyes de los Césares, otras son las leyes de Jesucristo». Pero al hacerlo Gelasio frente al emperador, consolidó la doctrina de colaboración que pretendía servir de inspiración en las relaciones entre la Iglesia y el Imperio. Así como la Iglesia no debía intervenir en asuntos temporales, tampoco el emperador debía inmiscuirse en su dominio. Sin embargo, este debía estar sometido a la Iglesia en materias religiosas, pues el papa es responsable ante Dios por el emperador.

Esta concepción dual del mundo y en consecuencia dual también del poder será, como veremos, importantísima en todo el desarrollo de la historia de la cristiandad oriental y occidental. En Oriente es sin duda donde la materialización de esta dualidad es más patente, pues las dos instituciones en las que la dualidad de poderes se plasma, la Iglesia y el Imperio, continúan vivas y fuertes hasta principios del segundo milenio. Esas dos instituciones gobiernan ese mundo dual que se parte también en dos comunidades, la *politeia*, es decir, la comunidad política, y la *ekklesia*, la comunidad espiritual. Dos comunidades que, por lo demás, se acercan una a la otra; tanto, que el derecho imperial poco a poco adopta criterios de raíz cristiana para definir quiénes forman parte de la comunidad política en función de las nuevas maneras de entender las categorías de «otros» y de «nosotros» como paganos y cristianos.

Como no podía ser de otra forma, también el derecho es dual. De cada poder emana un derecho propio de ese ámbito al que pertenece y que pretende regir en la comunidad a la que está dirigido.

Cierto es que esos derechos no operan de forma aislada; la influencia mutua es desde el principio muy fuerte, como también lo es la influencia entre ambos poderes, y como también ambas comunidades, la *politeia* y la *ekklesia*, están mezcladas en este mundo. Aunque, al decir de Gelasio, el poder espiritual pretende una supervisión sobre el temporal –pues ambos en definitiva deben estar sometidos al objetivo último de la salvación–, será común ver, sobre todo en Oriente, intentos de una supervisión del poder político sobre el espiritual y también injerencias excesivas del poder espiritual sobre el temporal.

A pesar de eso, tanto los poderes como los derechos están conceptualmente definidos: el **derecho civil** es el derecho del Imperio, el derecho de los poderes de este mundo, el **derecho canónico** rige la comunidad de los cristianos.

Veremos cómo esta división, que en Oriente tuvo un gran y muy detallado desarrollo desde el siglo V, en Occidente es más débil durante la Alta Edad Media; aunque se hace fuerte sobre todo desde el final del primer milenio.

En Occidente, después del siglo V, como ya hemos señalado, no existe una institución con efectividad real que herede la pretensión universal del Imperio. Esa continuidad se da, lógicamente, allí donde continua vivo el Imperio, es decir, en el Mediterráneo oriental. En cambio, en la Europa latina fragmentada en reinos fundados por pueblos germanos romanizados, el ejercicio del poder temporal recae en sus reyes; la única institución universal es, por tanto, la Iglesia y su organización institucional. Allí la Iglesia es el gran factor de unidad, lo único que permite hablar de un solo mundo, de un nosotros respecto de todo ese espacio y pueblos divididos. Volveremos sobre este asunto.

4.1. Nosotros los cristianos

En su *De civitate Dei* (*Sobre la Ciudad de Dios*), Agustín de Hipona formula una visión de la historia que nos es especialmente interesante en este punto. Agustín afirma que dos amores fundaron dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. La primera está fundada sobre el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la segunda en el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Es interesante ver que en el pensamiento de Agustín existe también el desdoblamiento del mundo. La Ciudad de Dios es pasajera en este mundo y no pertenece a él, sino que peregrina por la tierra para llegar a su destino, que está en el más allá. Pero mientras se encuentra en ese peregrinar está mezclada en este mundo con la ciudad del hombre. No se puede saber a qué ciudad pertenece cada hombre, ni a cuál pertenecerá al final de su historia personal. Más allá de la visión de la historia que construye Agustín, lo interesante para nosotros es que el obispo de Hipona lo hace sobre el concepto de **ciudadanía**, el mismo que aportó Roma y que se convirtió en la primera noción de un «nosotros» universal que unificó el mundo mediterráneo. Ahora, Agustín habla también de ciudades, no de una, sino de dos. Y su planteamiento solo se puede entender desde la óptica de la ciudadanía romana concebida como una red de relaciones interpersonales y no como un vínculo personal con una institución o un territorio.

Por eso, las ciudades pueden estar mezcladas, pues ni la Ciudad del Hombre ni la Ciudad de Dios existen físicamente, sino como una realidad construida sobre los vínculos que establecen entre sí las personas y estas con Dios.

Los cristianos pertenecen a una ciudad a la que se ingresa por la profesión de la fe y la vida consecuente con dicha profesión; todo aquel que la confiese pasa a ser ciudadano. En ese sentido, la ciudad de Dios es más inclusiva, es fácil formar parte de esa red de relaciones, pues no depende del reconocimiento

Agustín de Hipona

Agustín de Hipona nació en Tagaste en 354 y murió en Hipona en el año 430 (ambas ciudades están en la actual Argelia). Después de su conversión tardía a los treinta y tres años de edad, se transformó en uno de los pensadores más importantes del mundo cristiano. Las *Confesiones* y la mencionada *Ciudad de Dios* son sus obras más importantes.

de una condición por parte de un poder público. Desde otra perspectiva es más excluyente, pues exige una profesión de fe monoteísta. Por su parte, la ciudadanía romana suponía la incorporación de la religión oficial entre el cúmulo de cultos, por regla general politeístas, que profesaban los habitantes del Imperio. Pero eso no suponía mayor contradicción espiritual para los ciudadanos romanos, pues primaba en el mundo antiguo el sincretismo religioso; los dioses de distintos pueblos circulaban por el Mediterráneo y una persona podía profesar muchos de los credos sin negar ninguno. Por eso los cristianos y judíos fueron perseguidos, no por sus creencias, sino por no estar dispuestos a aceptar la religión oficial, pues, en su condición de monoteístas, sí suponía una contradicción espiritual insuperable.

La cristianización del Imperio fue un proceso largo; en dicho periodo se dieron persecuciones intermitentes y más o menos intensas según la época. Fue precisamente en el ejemplo de los mártires que rechazaban la apostasía y se negaban a practicar –además del propio– el culto oficial del Imperio, sobre quienes se fundó el espíritu y la primera doctrina de la Iglesia. Su ejemplo enardecía a las comunidades cristianas que se extendieron poco a poco; en un principio en Grecia, sobre todo, y luego en todo el mundo, que entonces constituía una unidad bajo la idea de ciudadanía. Para tiempos de Agustín el proceso de cristianización se hallaba próximo a culminar. De hecho, su obra es precisamente un llamado a la conversión, pues está escrita contra aquellos que no profesan la fe cristiana.

Como ya señalamos, en el año 380 Teodosio dio carácter oficial a la religión cristiana; desde entonces la idea de «nosotros» que unificó el Mediterráneo fue la de un «nosotros» cristiano que, por su propia naturaleza, pretendía ser universal.

Ese «nosotros» se fundó en la misma idea de ciudadanía, pero ahora no ya «tecnificada», como definimos la ciudadanía romana, sino fundada en una visión de carácter religioso.

Poco después, Agustín fue testigo de las invasiones que llevaron a cabo los pueblos germanos en los territorios que habían estado durante siglos bajo la administración romana y que pocas veces habían sido invadidos y expoliados. En su tiempo fue ocupada y saqueada por los visigodos la propia ciudad de Roma. Desde esa perspectiva escribe el obispo de Hipona, en un mundo en el que el poder imperial se adelgazaba al punto de anunciar su próxima desaparición. En su visión era la unidad que brindaba la Iglesia y la ciudadanía espiritual la única posible.

En Oriente, las cosas no se dieron de la misma manera, pues, como hemos señalado, allí el Imperio seguía en pie y seguiría estándolo, con altos y bajos, durante mil años más. Por eso, en el Imperio Romano que subsiste al desmem-

bramamiento de su parte latina las dos ciudadanías conviven, pero la ciudadanía romana es una ciudadanía también cristiana. En Occidente, el relato de un nosotros que permite hilvanar las redes sociales y que da unidad al mundo será el de la Iglesia solamente, al menos mientras no renazca de manera más o menos eficaz la idea imperial.

Desde el año 476 no había emperadores en Occidente. El emperador de Constantinopla se consideraba el único titular del Imperio universal. Sin embargo, en el año 800 el Occidente latino protagonizó el primer intento por renovar la noción imperial y, con ella, la unidad política bajo el alero de los francos y su rey Carlomagno. Se trata de una noción imperial basada en la nostalgia de la antigua Roma y fundada también sobre la idea de un Imperio Cristiano⁵. Ahora nos interesa recalcar que la coronación de Carlomagno como emperador asestó un duro golpe a la unidad del mundo cristiano que provocó una herida en las relaciones entre uno y otro lado de la cristiandad; desde entonces, se distanciarían cada vez más.

Cuando Carlomagno fue coronado emperador romano, en Oriente gobernaba Irene, que también ostentaba el título de reina de los romanos. No obstante, la emperatriz se encontraba en un momento de debilidad política, pues su legitimidad era cuestionada en el interior del Imperio. Este resurgimiento de la idea imperial en Occidente, más allá de su escaso éxito, inaugura un camino de separación inexorable entre los dos mundos cristianos que culminará con el cisma de las iglesias en el año 1054. Con ello quedaban separados ambos lados del Mediterráneo tanto en el plano temporal como en el espiritual. Occidente comienza así un camino divergente e independiente del Imperio Romano de Oriente al que había estado unido simbólicamente en el plano temporal por el trono imperial y, efectivamente, por el poder espiritual de la Iglesia. La idea de un nosotros político y religioso que unificara la Europa latina era por primera vez un proyecto en marcha. Por eso es que, para referirnos a ese mundo, decimos cristiandad, y en particular desde el año 1054, cristiandad latina para distinguirla de la oriental, pues hasta ese momento, con muchos conflictos por cierto, tanto Oriente como Occidente formaban parte de una misma e indivisa comunidad religiosa.

4.2. Cristianismo y persona

Los griegos dieron al término **persona** el contenido de supuesto intelectual de una naturaleza y los romanos, en cambio, uno relativo a la posición que ocupa el hombre en las relaciones con otros (padre, hijo, vendedor). El cristianismo dotó de un nuevo contenido a la palabra, más alto que el griego y más permanente que el romano. Bajo el amparo de esta distinción entre lo sagrado y lo profano, el cristianismo propuso una idea de persona que, en su condición de hijo de Dios, es dueño de sí y de sus actos, y responsable de los mismos ante el Creador.

⁽⁵⁾Volveremos a tratar sobre este periodo en el módulo «Lec-
ción II: Fundamentos históricos del
derecho. La Europa medieval (s.
IX-XV)».

Carlomagno e Irene

Para evitar el conflicto político y unir las dos casas se barajó la posibilidad del matrimonio entre Carlomagno e Irene; sin embargo, la deposición y muerte de la emperatriz dejó trunco el plan que tal vez hubiera dado lugar a una historia muy distinta de la que conocemos.

La dignidad de persona confiere al hombre un nuevo puesto en el cosmos. Le acerca a Dios y lo coloca a una distancia inconmensurable por encima del resto de las creaturas. Deja de ser aquel modesto animal racional o la medida de todas las cosas en que los griegos cifraban su dignidad, pero que, en definitiva, no pasaba de ser algo transitorio y, como tal, sujeto al grupo en que se hallaba inserto, que era lo permanente, fuera estirpe, tribu, ciudad, nación, país o estado.

El puesto de la **persona** en el cosmos, en el pensamiento cristiano, no depende del o los grupos de que forma parte, ni de lo que tiene, ni del estado en que se encuentra, ni de ninguna cosa de este mundo. Esta fue la clave para relativizar las diferencias del más acá terreno, todas pasajeras: raza, lengua, creencias, saber, poder, riqueza, hombre, mujer, ciudadano, peregrino, libre, esclavo.

El mensaje evangélico es terminante en este sentido:

«No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois por tanto, descendencia de Abraham, y herederos según la promesa.»

(Gal. 3, 28-29).

Esta es la nueva ciudadanía cristiana a la que nos referíamos más arriba.

En la práctica, esto se traduce en que el hombre cesa de ser tan solo un miembro más de la cadena de generaciones dentro del grupo al que pertenece. Su dependencia al respecto comienza a aflojarse y, poco a poco, se halla en condiciones de decidir y actuar con cierta independencia en una serie de órdenes: matrimonio, profesión, residencia, etc. Varias de estas ideas se hallaban en ciernes e incluso bien desarrolladas en movimientos filosóficos en la época de expansión del cristianismo. Los primeros cristianos, en la medida que las encuentran coincidentes con el mensaje evangélico, las incorporan y les dan un fundamento sobrenatural en la Revelación. Naturalmente, esta relativización de las diferencias de este mundo no se impone de golpe; su avance, lleno de retrocesos, por cierto, requiere de siglos para conseguir algunas parcelas en un mundo que hoy mismo sigue sin aceptar este u otro mensaje así de radical. No obstante, el cristianismo, ya en esa época, en un intento por restaurar la igualdad natural del hombre frente a los atropellos de este mundo, dio un importante sitio a la caridad y, en el plano del derecho, la moral influyó fuertemente en pos de favorecer a las personas miserables y a los que son objeto de abusos.

4.3. Cristianización del derecho romano

Ha habido un debate interminable entre los historiadores y romanistas en el intento de discernir si tal o cual institución tiene origen cristiano o pagano. Esto vale especialmente para los primeros tiempos de los emperadores cristianos, cuando ya el cristianismo se había extendido por todo el Imperio pero convivía con el mundo pagano. Sobre esta época hay, pues, consenso entre los romanistas a la hora de afirmar que se ha inaugurado una nueva era en el derecho; sin embargo, no existe el mismo acuerdo a la hora de atribuir esos cambios a la influencia de la doctrina cristiana.

Legislación matrimonial

Por ejemplo, en materia de familia se ha discutido últimamente si la legislación matrimonial de Constantino responde a una visión cristiana o a otras valoraciones sociales que por entonces circulaban.

La verdad es que resulta complicado sostener una u otra cosa, pues cualquiera de las dos podría conducirnos a pensar que el cristianismo permaneció ajeno a las corrientes de pensamiento y costumbres de su época. Si una determinada institución sufrió una mutación en el periodo cristiano en razón de las ideas que por aquel entonces inundaban la vida política y social, y dicho cambio resultó luego ser compatible con el cristianismo, el cambio es, en último término, alentado, incorporado o al menos tolerado desde el mundo cristiano.

Por una razón muy sencilla, el cristianismo no fue necesariamente la fuente de todos los cambios morales de la Antigüedad tardía, eso es evidente, antes bien se unió a ellos en lo que fueran favorables al mensaje de Cristo. El cristianismo, en definitiva, es en esta época la justificación de la vida social.

Hablábamos al principio de la necesidad de la historia, de los relatos que construyen la civilización. Pues bien, en esta época, tal como lo ve san Agustín, el cristianismo se convierte en ese relato para la sociedad de entonces y la que vendrá. En ese relato se incorporan otros preexistentes.

Así, por ejemplo, muchas de las enseñanzas de la filosofía estoica, el cristianismo las hizo suyas por considerarlas buenas. Los estoicos habían renovado la antigua ascesis romana con un nuevo sentido, ensalzaron la imagen de la mujer casta (al igual que la del hombre casto), rechazaron la exposición de neonatos, y, en fin, sentaron las bases de lo que constituiría la nueva moral sexual romana y cristiana. Bajo el signo de esa escuela filosófica que orientó la vida amorosa hacia el matrimonio y la procreación, la moral social recogió algunas costumbres inmemoriales como la mujer *univira* (que tiene solo un marido y no vuelve a casarse al enviudar), que es revalorada en su máxima expresión. También se intenta evitar el divorcio, aunque la Iglesia no logró nunca proscribirlo totalmente sino hasta después de mil años.

Lo que perduró de esos cambios, lo que los consolidó en el mundo jurídico y social, fue el cristianismo, que se transformó rápidamente en el fundamento primero de aquella sociedad y de la que le sucedió. El cristianismo, como hemos insinuado antes, en muchos casos elevó la simple tradición o costumbre al plano de lo sagrado y con eso la dotó de perdurabilidad. En otros, a un elemento preexistente pero accesorio en el acervo moral grecorromano lo convirtió en el centro o en la base moral de una institución.

A la larga toda la sociedad romana y, por ende, por la tolerancia, la innovación o la supresión de alguna institución, también todo el derecho, se vio penetrado por las ideas cristianas y el cristianismo también se vio empapado del mundo en el que se instaló.

En esa convergencia de ideas, la noción cristiana de **persona** es clave para entender el desarrollo de las instituciones romanas. No solo el poder y el gobierno se vieron inundados de ella, también la familia, la propiedad y la esclavitud. Pero, como se ha dicho, no es un cambio violento, no se trata de una revolución.

La influencia es lenta, aun cuando el cristianismo se hallaba muy extendido seguía debatiendo con la moral pagana, integrándola a veces, condenándola otras, y la nueva doctrina no era del todo aceptada por los emperadores. Tan solo en la normativa imperial producida entre los siglos IV y VI puede apreciarse con mayor claridad la influencia. Aun así, la cristianización del derecho romano no llegó nunca a ser completa. En materia matrimonial, por ejemplo, como en muchos otros aspectos, en el siglo V y más adelante persisten las contradicciones.

En cuanto a la propiedad, la influencia cristiana no se aprecia en las reglas que no cambian de manera ostensible, sino en la forma de entenderlas. Se considera que los bienes son medios al servicio de la persona y, en general, de todos los hombres. Por tanto, se rechaza el apego a ellos, que lleva a la persona a subordinarse a lo que tiene como si fuera un fin, y se estimula, en cambio, el desprendimiento, sobre todo a favor de los necesitados, de la Iglesia y de las instituciones de beneficencia que, desconocidas en el mundo antiguo, surgen bajo el alero de esta con gran empuje. Esta enseñanza supuso también que la Iglesia se enriqueciera y se convirtiera en terrateniente. Como es lógico, también la convirtió en objeto de la apetencia de las familias aristocráticas y la introdujo a la larga en el juego de poderes oligárquicos que protagonizará la vida política de la Europa latina a partir del año 1000.

En cuanto al derecho de familia, la ya debilitada *patria potestas* se tornó en favor de los hijos y no ya en una herramienta jurídica de dominación y delimitación de la familia. Lo mismo puede decirse del control que sobre la mujer pudiera ejercer el marido. En general, el uso del poder se ve reorientado, al menos en teoría, en beneficio de los sometidos a él. De los restos de la *patria potestas* se construyó una relación de deberes y derechos con los hijos y aparecieron ciertas obligaciones que repercutieron en su independencia material. Al ya en desuso derecho sobre la vida y la muerte del hijo, los Padres de la Iglesia contraponen el sacrificio de Dios que entrega a su hijo en sacrificio por amor.

Por lo demás, la gran influencia del cristianismo sobre el derecho es, por una parte, haber determinado cómo leer el derecho antiguo.

No se trataba, pues, de cambiar muchas cosas; el cristianismo aceptó en su mayoría la organización social precedente, se trataba simplemente de leer las reglas con otros ojos, insertas dentro de un orden universal querido por Dios, como veremos en los apartados siguientes.

Por otra parte, la influencia del cristianismo vino a través de la creación del **derecho canónico**, que tendrá un papel fundamental en la construcción jurídica de Europa occidental y oriental.

Ya nos hemos referido a ese derecho como una expresión del desdoblamiento del mundo que ha operado por obra del cristianismo. También hemos dicho que los poderes, el espiritual y temporal, se influyen mutuamente; lo mismo sucederá con el derecho canónico y el derecho civil, que conviven como dos ordenamientos fundamentales en dicha sociedad y que se comunican instituciones, principios y reglas.

5. La Antigüedad tardía y el desmembramiento de Occidente (s. III-VI d. C.)

La Antigüedad tardía es un periodo que comparte rasgos de la Antigüedad clásica y de la Alta Edad Media. Ya advertimos que las cronologías son artificios y como tal encierran el peligro de falsear la realidad. Las sociedades no suelen cambiar repentinamente; por eso es importante entender que todo aquello que caracteriza a una época ya se encuentra muchas veces presente en la anterior. Es por ello muy interesante el estudio de este periodo y, en especial, los cambios que obran durante su desarrollo en la sociedad y en el derecho. Factores como el cristianismo, la preponderancia del poder imperial frente a los demás poderes sociales, el posterior desmembramiento de la parte occidental del Imperio, la incorporación de los pueblos germanos en la geografía cultural del Mediterráneo son, entre otros, algunos elementos que la caracterizan. Nos interesa tratar aquí sobre la transformación del escenario político que se produjo en esta época; para ello recapitulemos primero algunos antecedentes que hunden sus raíces en la temprana Antigüedad y que nos permiten entender mejor estos fenómenos.

5.1. Antecedentes

Roma nació en la periferia del mundo. El centro de la actividad cultural, económica y tecnológica en el contexto euroasiático estaba y había estado siempre en el Cercano Oriente. Las primeras civilizaciones habían florecido allí y habían dado lugar a grandes extensiones políticas en Mesopotamia, en Egipto y en general en Oriente Medio. Era dicha zona y el Mediterráneo oriental la que se hallaba conectada por vínculos políticos, culturales, lingüísticos y económicos. Siglos antes de que Roma dominara el Mediterráneo, el mundo asistió al florecer de la cultura griega. Pero los helenos también estaban en la periferia del mundo. El centro en su tiempo estaba en el corazón del Imperio Persa y en Egipto. Hacia Occidente, en la actual Europa, no se habían formado ni grandes imperios ni civilizaciones complejas como en Oriente. Se trataba, pues, de un mundo fragmentado política y culturalmente, predominantemente en estado tribal. Por eso los griegos estaban justo en el límite del mundo por entonces civilizado (en el sentido que hemos explicado más arriba). De hecho, los siglos VI y V a. C. fueron críticos para la civilización helénica, pues ese centro del mundo se les abalanzó y los griegos se vieron obligados a la guerra para preservar su independencia del Imperio Persa. Nos referimos a las famosas Guerras Médicas que, a la postre, permitieron a los griegos un desarrollo cultural autónomo políticamente.

La expansión de los griegos se limitó a la fundación de ciudades en ambas costas del Egeo y hacia el oeste, sobre todo en la península itálica e incluso en la península ibérica. Sin embargo, su expansión no revistió un carácter imperial.

Los griegos no pretendieron dominar los territorios en los que se asentaban más allá del límite de la *polis*. Esa era, como ya anunciábamos en el primer capítulo, su impronta política. Esas ciudades irradiaron, como no podía ser de otra forma, la cultura griega por el Mediterráneo, pero los helenos no lograron ni pretendieron una unidad política y cultural de todos aquellos territorios en los que se hicieron presentes. Por tanto, el Mediterráneo occidental, en tiempo de la expansión romana, seguía siendo un territorio carente de unidad lingüística, política y cultural.

En el Mediterráneo oriental, en cambio, la situación era distinta. Ya comentamos arriba que el siglo IV a. C. había significado una ruptura en la tradición política de la *polis*. De la mano de Alejandro Magno, Grecia se unificó políticamente, y no solo eso, también inició una expansión hacia aquel Oriente poderoso al que los griegos hasta entonces solo habían podido rechazar militarmente. La Grecia de la periferia se lanzaba a la conquista del centro del mundo. Esa conquista que, como dijimos, fue efímera, propició no obstante una cierta unidad cultural en el Mediterráneo oriental; dicha unidad se manifestaba sobre todo en redes comerciales, relaciones políticas estables y la lengua griega como lengua vehicular, sobre todo de la cultura.

Eso supuso que, en su expansión hacia Oriente, los romanos se encontraran con un mundo muy distinto al occidental, pues ya gozaba de cierta unidad lingüística, cultural y política. El sentido práctico de los romanos aprovechó esta situación y desde entonces, en la zona oriental del Imperio, además del latín, se continuó usando el griego.

Incluso documentos de la Administración eran evacuados en esta lengua, aunque en lo que respecta al derecho siempre el latín fue hegemónico. Aquello que los romanos consideraban su gran aportación a la civilización, el derecho, mantuvo su impronta primordialmente latina hasta tiempos de Justiniano. Pero el Imperio ya presentaba dos orillas bien diferenciadas, y dicha diferenciación, como veremos, se irá agudizando con el tiempo.

Edicto de Caracalla

Por ejemplo, el texto del Edicto de Caracalla (212 d. C.), al que hicimos mención y por el que se concedió la ciudadanía a los habitantes libres del Imperio, lo conocemos por un papiro escrito en griego.

5.2. Dos mundos de un mundo, el desmembramiento

El lado oriental del Imperio, como había sido desde antiguo, siguió ejerciendo un poder magnético.

Tanto que, después de siglos de hegemonía de la ciudad de Roma, el emperador Constantino, en el año 330 d. C., finalmente convirtió Constantinopla en la ciudad más importante del Imperio.

No significó esto que Roma perdiera su dignidad y su carácter capitalino, pero el centro, el corazón de la administración y del poder del Mediterráneo ya no volverían a estar nunca más entre sus murallas, al menos durante el siguiente milenio. Constantinopla, fundada sobre una antigua colonia griega llamada Bizancio, ubicada sobre el estrecho del Bósforo, uno de los puntos geopolíticamente más importantes de la época, se trasformó en la nueva ciudad, la ciudad más importante del mundo.

Mientras tanto, el Imperio debía afrontar la entrada de numerosas tribus de pueblos germanos que se veían presionados por otros pueblos, como los hunos, que se trasladaban desde Oriente ocupando sus territorios. Estos pueblos entraron como colectivos en el Imperio, en ocasiones pacíficamente y en otras en actitud beligerante. Sus reyes celebraron tratados con los emperadores romanos y fueron ganando espacios en la sociedad de la época, sobre todo como milicia para engrosar las filas del ejército. Los emperadores se sirvieron de estos pueblos para enfrentar a otros pueblos rebeldes dentro o fuera de las fronteras del Imperio, incluso a otros pueblos germanos. Este asentamiento paulatino generó una progresiva integración de dichas poblaciones en la sociedad latina, en ese «nosotros» del que hablamos al principio de este apartado. Aunque su asimilación a la cultura romana no fue óptima, en el siglo V d. C. muchos cabecillas de los pueblos germanos gobernaban en nombre del emperador como magistrados en distintas regiones del Imperio. Muchos de ellos, incluso, accedieron a los círculos imperiales.

El asentamiento, no obstante, se produjo sobre todo en el lado occidental del Imperio, en lo que se transformará en la Cristiandad latina.

Oriente resistió mejor y rechazó las migraciones de pueblos germanos; en cambio, la parte occidental se vio poco a poco gobernada por los reyes de esos reinos, primero en nombre del emperador y, cuando el Imperio se debilitó al punto de no ofrecer nada a cambio de esa sumisión, en nombre propio como monarcas de sus pueblos.

En otras palabras, sus líderes se independizaron de la figura imperial y rigieron, sin pretensiones de universalidad, el devenir político de sus pueblos. Entre estos pueblos encontramos a los visigodos, los burgundios, los francos y los longobardos.

Desde el punto de vista constantinopolitano, entre los siglos V y VII gran parte de la zona occidental del Imperio se desmembró. En Occidente, en cambio, tradicionalmente se habla de la caída del Imperio Romano; en ocasiones, se aclara que se hace referencia a la caída de la parte occidental. Es cierto que, por iniciativa del emperador Dioclesiano (siglo III d. C.), administrativamente el Imperio se había dividido en dos e incluso cuatro, pues cada una de estas zonas se subdividía a su vez en dos, una de mayor jerarquía que la otra. Cada una

de las dos partes principales, la de Oriente y Occidente, tenía su propio emperador, aunque desde Constantino la cabeza del Imperio se entendía perteneciente a Constantinopla. Eso no obsta a que siguiera existiendo una noción de Roma como una urbe universal, la división respondía más bien a necesidades administrativas. El derecho, por ejemplo, circulaba entre una parte y otra, tanto que era común que el emperador de una parte promulgara en la suya leyes dictadas por el emperador de la otra. Es el caso del Código Teodosiano al que hemos hecho mención, que fue promulgado en el año 438 por Teodosio II para Oriente y un año más tarde por Valentiniano III para Occidente. La referencia a este código no es casual, pues será precisamente dicha recopilación de normas la pieza que servirá de base para el derecho escrito durante la Alta Edad Media en Occidente.

Los hechos, pues, podrían leerse como la separación de una de las dos vertientes del Mediterráneo respecto de la unidad política y económica que el Imperio había generado y que siguió viva en Oriente.

En cambio, de las ruinas del Imperio en Occidente se formarán numerosos reinos gobernados por élites germánicas y también romanas que lograron asimilarse a la nueva clase dirigente. Esos reinos tendrán una importante influencia germánica. No obstante el sustrato cultural que proporcionó el mundo romano, y puesto que la mayoría de la población podía considerarse descendiente de ese mundo, la impronta de esos reinos es también y en muchos casos preponderantemente romana.

En Oriente dicha unidad política y cultural se mantuvo, no obstante, con muchas dificultades. De modo que el Imperio Romano siguió existiendo sin solución de continuidad en esa mitad del Mediterráneo hasta 1453⁶.

⁽⁶⁾Véase el apartado «La Antigüedad tardía y el derecho» del presente módulo.

Vemos, pues, que entre los siglos V y VII el panorama geopolítico había cambiado bastante. Distingamos tres escenarios: el occidente y el oriente del Mediterráneo norte y el Mediterráneo sur.

El **occidente del Mediterráneo** quedó fragmentado políticamente dominado por pueblos germanos romanizados en distinto grado.

Como ya advertimos, allí nadie heredó la vocación universal del Imperio, la única institución universal que de alguna manera unificaba esa zona era la Iglesia. La cultura letrada siguió cultivándose en latín, pero tuvo poco alcance popular, pues se trató de una cultura que se conservó sobre todo en los monasterios. La sociedad en general vivió en el escenario de la oralidad. Las redes comerciales decayeron y la vida social se simplificó; la villa pequeña sería en adelante, y por varios siglos, el escenario más corriente de la vida.

La situación en el **Mediterráneo oriental** es muy distinta en algunos aspectos, pero no tanto en otros.

Hasta el siglo VI, la crisis que ya venía azotando al Imperio, al menos desde el siglo anterior, allí no fue tan notoria. Sin embargo, después de ese siglo, y en particular tras el reinado del emperador Justiniano, también el Oriente cristiano se sumió en una crisis social y económica. No obstante, la institucionalidad del Imperio siguió proveyendo de unidad a ese mundo y asegurando algunas comunicaciones y redes comerciales. Aun así, el Oriente romano también experimentó una progresiva simplificación de la vida social y la ruralización de gran parte de la población que solía ser urbana. El derecho, con muchos matices, compartirá varios elementos con el derecho de la cristiandad occidental. Volveremos sobre este asunto más adelante.

El **Mediterráneo sur** sufrió una gran transformación al menos en el plano espiritual.

Desde el inicio de su expansión en el siglo VII, el islam se hizo imparable, al menos hasta que se acercó al corazón del Imperio Romano en Constantinopla. Las regiones del sur y sureste mediterráneo fueron dominadas por señores musulmanes. La pérdida de estas provincias tuvo duras consecuencias para el Imperio Romano, pues estaban entre las regiones más ricas del mundo. De hecho, muchos elementos culturales que normalmente se asocian al islam estaban en realidad presentes en estas zonas antes de las nuevas conquistas, y gracias al esplendor cultural que experimentara el califato muchos de ellos se mantuvieron vivos y llegarían a Occidente a través de la península ibérica. Incluso algunas de las obras científicas más importantes del mundo antiguo serían recobradas en Occidente no solo en griego desde el Imperio Romano oriental, sino traducidas desde el árabe.

Baste decir que la irrupción del islam⁷ supuso la ruptura de la unidad espiritual del Mediterráneo. Hasta ese momento, y desde la expansión y generalización del cristianismo, ambos nosotros, el romano y el cristiano habían sido los dos relatos que daban sentido a la convivencia política.

⁽⁷⁾No trataremos en el cuerpo de estos materiales el derecho islámico, para eso nos valdremos de textos complementarios.

Desde este momento nos encontramos con tres relatos distintos, dos de ellos hermanos y uno algo más lejano. La cristiandad, que aún no se hallaba dividida espiritualmente, pues no se había producido el Cisma de Occidente (1054 d. C.), se hallaba dividida políticamente: en Oriente el relato de lo romano seguía vivo, mientras que en Occidente la fragmentación política en reinos

independientes unos de otros era la regla. En esta zona el relato que sobrevivió e hizo de alguna forma sobrevivir al nosotros romano, al menos de forma latente, fue el relato político cristiano.

Veremos también cómo esta división política terminó por transformarse también en una división religiosa cuando la Iglesia oriental y la occidental acabaron por separarse. Lo interesante es ver cómo esa separación se corresponde con la apreciación que hacíamos al principio: Oriente siempre tuvo características muy distintas a Occidente, desde la expansión romana. Esas diferencias se mantuvieron incluso en lo lingüístico: el mundo oriental fue predominantemente de habla griega, el occidental latina y sus dialectos. Volveremos también sobre este punto en los apartados siguientes. El tercer relato que irrumpe en el escenario mediterráneo es el islam, que, como ya señalamos, no trataremos aquí. El Imperio Romano tuvo que hacer frente desde sus comienzos a la expansión islámica. La Europa latina también tuvo que resistir al islam desde temprano en el sur de Italia, pero sobre todo desde la arremetida por la península ibérica a principios del siglo VIII.

Esta nueva realidad determinó, como no podía ser de otra forma, la impronta del derecho de esta época. Lo analizaremos respecto de las dos partes del Mediterráneo cristiano, la del Imperio y la Europa latina fragmentada.



5.3. La Antigüedad tardía y el derecho

Como venimos advirtiéndolo, tanto en el Occidente como en el Oriente cristiano los siglos IV-VII representaron un tiempo de crisis y de incertezas. No solo de la actividad jurídica, sino también del orden social y económico. Esta crisis terminó por desmembrar la parte occidental del Imperio y cambiar profundamente la oriental, provocando también la ruralización de la vida social y económica del Mediterráneo. Si bien en Oriente el Imperio sobrevivió e incluso, en tiempos de Justiniano, recuperó una parte de los territorios occiden-

tales que se habían desmembrado, después de la muerte de dicho emperador se sumió en una crisis de la que se recuperaría solo a partir del siglo VIII. De modo que, como hemos descrito más arriba, la Europa latina, separada del Imperio, estará conformada por una serie de reinos comandados por las élites de los pueblos germanos que habían ido asentándose dentro de los límites del Imperio; por su parte, Oriente mantendrá su unidad política bajo el signo de un Imperio Romano debilitado.

En Occidente, la simplificación del quehacer jurídico comenzó antes y acabó más tarde. En efecto, ya en los siglos IV y V es evidente que el cultivo del derecho no es el de la época clásica, sino que se ha hecho más tosco lingüística y técnicamente.

Tanto es así que, en lo que respecta a la Europa latina, no volverá a haber propiamente ciencia jurídica hasta principios del segundo milenio.

Este fenómeno hunde sus raíces mucho antes del siglo V. Por eso, en buena medida la impronta del derecho, si bien con muchos matices, no es tan distinta en el Oriente y el Occidente cristiano durante la Edad Media. La razón es que los factores que subyacen a la crisis tienen su origen antes de la separación política de ambas vertientes del Mediterráneo y, además, que las causas posteriores a dicha separación son en buena parte comunes a ambos espacios. En efecto, hay muchas explicaciones para este fenómeno: no solo es la enorme injerencia que el poder imperial tuvo desde la época del Dominado sobre todos los ámbitos de la vida, desplazando la creación libre de los juristas y sustituyéndola por la creación jurídica de manos del emperador. También sucede que el propio modelo de vida social que había extendido Roma por todo el Mediterráneo entra también en decadencia. En efecto, la ciudad de Roma, que, como hemos advertido, es un concepto inmaterial, un espacio cultural más que una urbe, se había sostenido en la red de relaciones que brindaba la ciudadanía, y esa ciudadanía se había extendido sobre la red que formaban las distintas ciudades del Imperio. Dichas ciudades o municipios se erigieron o se remodelaron a imagen de Roma, se establecieron asambleas, magistraturas y, en fin, se procuró que las urbes del Imperio estuvieran en comunión con ese modelo de vida. En ese marco se desenvolvía el derecho civil y su cultivo.

Es difícil imaginar el desarrollo de una comunidad de cultores, los juristas, en un medio aislado y rural; también es difícil que su labor tenga impacto práctico en un medio de esa naturaleza. Por eso, la ciudad era el medio natural en el que un derecho de las características del *ius civile* (la propia palabra nos da pista de ello) podía desarrollarse.

Sin embargo, desde el siglo III el peso del aparato público, la crisis económica y la inseguridad de dichos centros urbanos se torna cada vez más gravosa para sus habitantes. Esto llevará a una paulatina ruralización de la población y la consecuente degradación del modelo social que hasta entonces imperaba.

Este fenómeno fue sin duda mucho más acusado en Occidente. En Oriente, aunque la crisis duró menos tiempo, también supuso, no obstante, que el gran acervo jurídico heredado de la Antigüedad fuera utilizado solo en parte y que, como en Occidente, primara una comprensión pragmática y sintetizada de dichas fuentes y que se privilegiara la costumbre.

La **ciencia jurídica** fue poco a poco absorbida por las demás artes liberales y perdió la identidad y singularidad que había tenido hasta tiempos de Justiniano.

Pero este fenómeno se produjo con intensidad solo después de la muerte de este emperador, en el siglo VI, y acabó en el siglo IX, cuando renacieron los estudios de derecho en el Imperio Oriental.

Este cambio profundo en la dinámica de vida del mundo cristiano oriental y occidental determinó, a su vez, profundos cambios en la concepción y en el uso del derecho. El fenómeno que tradicionalmente en la historiografía occidental se ha llamado **vulgarización del derecho**, en parte, es la adaptación de la técnica jurídica a una sociedad cuyas estructuras experimentaban una profunda crisis y que necesitaban de respuestas distintas a las que el derecho romano clásico podía proporcionar y en un modo distinto al que las proporcionaba. ¿De qué servían en ese mundo las exquisitas distinciones de los juristas? Pretender que ese derecho fuera conservado y practicado como antes sería como pretender hoy, después de un cataclismo nuclear, aplicar la ley de impuestos a la renta o hacer valer la fina doctrina civil en torno a las cuestiones de propiedad en una aldea aislada de supervivientes.

6. El derecho de la Europa latina y la edad de la nostalgia: Alta Edad Media (s. V-X)

En Occidente, las instituciones públicas que desaparecieron después de la crisis del siglo V que llevó al desmembramiento del Imperio exhibían una fisonomía de extrema delgadez. No hay un aparato público que sea capaz de intervenir de forma significativa en la realidad, ni tampoco que genere derecho nuevo. Si esta última noción ya venía en decadencia en el bajo Imperio, como ya hemos advertido, el fenómeno se incrementa en esta época. Recordemos que, ya desde los siglos III y IV d. C. las principales fuentes del derecho eran las constituciones imperiales (*leges*) y la opinión de los juristas antiguos (*iura*). La creación dinámica y libre de los juristas ocupaba un lugar cada vez más reducido y, con ello, el derecho perdía parte de su capacidad de adaptarse a la realidad llamada a regir. Durante la Alta Edad Media no se observa un desarrollo jurisprudencial del derecho y el conocimiento que se tiene de la opinión de los antiguos juristas es escaso. En cuanto a la ley, la otra gran fuente de los últimos siglos, es cierto que los reyes de los pueblos romano-germánicos serán sucesores de los emperadores en cuanto legisladores. Sin embargo, poco a poco es el **derecho local** consuetudinario el que acaba imponiéndose como la principal fuente del derecho. Tanto, que al final el derecho escrito debe presentarse como recopilación de ese derecho consuetudinario más que como actividad legislativa creadora de nuevo derecho. No significa esto que la costumbre discrepara por completo de los textos, pues su origen muchas veces es antiguo y proviene de las prácticas que antaño se regían por esas mismas normas escritas.

Es natural que así haya sido. En este mundo separado del Imperio y dividido políticamente, el aparato público no existe o se presenta en una forma distinta, débil, de corto alcance, ausente de la vida social de la villa o simplemente incompleto. Por ello es incapaz conceptualmente de crear derecho nuevo.

El nuevo poder político fragmentado no busca erigirse como un poder total, que gobierne la mayoría de los aspectos de la vida social, sino simplemente los imprescindibles para el desarrollo de su gobierno. Es un poder que no lo abarca todo, sino solo aquello que en cada acto político o legislativo le permiten sus fuerzas.

Es un poder que reconoce muchos límites, sobre todo en otros poderes, como el de la Iglesia o el que el colectivo de la sociedad y sus grupos representa.

Sin juristas y sin poder político suficientemente vigoroso especialmente desde el siglo V, el derecho que gobierna el devenir humano radica en los hechos. Es de esos hechos y de su repetición de donde emana. Es la naturaleza de las cosas, de los actos humanos y la naturaleza divina la que genera el derecho. Al hombre le corresponde descubrirlo.

En esta nueva actitud frente al fenómeno jurídico colabora el relativo aislamiento y la vida social contraída a pequeñas comunidades locales con una red política y social externa reducida a dimensiones muy pequeñas si se la compara con las que alcanzaba la administración imperial. En el escenario de esas comunidades políticas el derecho es un verdadero espíritu vivo, es aquello que se hace y se ha hecho y aquello que impone la propia naturaleza de las cosas, de este mundo y del otro. Los hechos, en definitiva, tienen una significación jurídica en potencia: es la realidad, sobre todo la de la tierra o la sangre, la que determina el lugar y el derecho de las personas. El derecho, por tanto, tiene un carácter factual, pues nace de la realidad física o metafísica y es descubierto por el hombre. Una forma didáctica de caracterizar al derecho de esta época es asimilarlo a las leyes que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. No se puede, por ejemplo, disponer que la sangre fluya en tal o cual sentido, ni ordenar que el hígado realice una función que no le es propia. Del mismo modo, la sociedad de la época, cuyo sentido colectivo y local se desarrolla fuertemente en ausencia de otras instancias políticas, se comporta como un cuerpo; y el derecho, lo que es justo, se descubre igual como se descubre (no se crea) el funcionamiento del cuerpo humano.

En un mundo como este no tiene sentido la figura del jurista.

No al modo en que lo entendíamos en Roma, como aquel experto en el arte de lo bueno y lo justo, aquel que maneja el lenguaje jurídico y, por tanto, todas sus distinciones y que es capaz de crear las soluciones para los casos que se le presentan y darle herramientas al juez para resolver. Ese saber de alto linaje resulta fuera de lugar en estas sociedades, y además es impracticable por su base rural. Si el derecho se descubre en los hechos y en la tradición que esos hechos generan basta con el sabio, con el hombre justo, con el juez, no es necesario el sabedor del derecho, pues el derecho está vivo en la sociedad misma, solo hace falta vivir en esa sociedad para conocerlo. El derecho no se presenta con un lenguaje particular, con una técnica que requiera una especialización, un saber diferenciado de otros saberes. Este derecho, a diferencia del derecho antiguo, se confunde con la moral o la religión en muchos aspectos. Ese fenómeno de diferenciación y refinamiento se dio en el marco de la ciudad, del municipio como reunión de personas, saberes y técnicas.

En este nuevo escenario de la villa, de la población dispersa y saberes concentrados en polos poco comunicados, la ciencia jurídica no tiene espacio.

Así es como desaparece, y entre los estudios de los saberes, el derecho no representará, hasta el año 1000 al menos, una disciplina distinta, con un metalenguaje diferente de los demás saberes y artes liberales. Será entonces cuando a este derecho consuetudinario enraizado en las sociedades de la época se lo oponga a otro universal y científico que proviene del pasado romano y que responde a las nuevas necesidades de la Europa latina.

Quien escribe el derecho y quien juzga, como hemos señalado, simplemente certifica, hace cierto un derecho dudoso, ignoto.

Hoy diríamos que el derecho de esta época es un derecho sin juristas y sin estado. Y decimos sin estado pues, desde la época de la revolución burguesa, hemos entendido que el estado se reserva el monopolio de la creación jurídica. En este mundo no hay nada parecido, ni lo habrá hasta los albores de dicha revolución. El poder político, allí donde se encuentra organizado y es influyente, abarca solo ciertos ámbitos de la vida social, regula solo pequeñas o grandes parcelas, pero parcelas al fin, del acontecer comunitario.

Como se descubre, el derecho es bueno. Tiene una carga ética fuerte que proviene del propio relato que ordena la sociedad. Hemos dicho que en esta época el relato político cristiano es la fuente de unidad y el fundamento mismo de la comunidad. Es el constituyente principal de la idea de nosotros. Pues bien, el derecho que se descubre es precisamente ese que ordena dicha sociedad como si fuera un cuerpo. Por eso usábamos arriba la analogía con las leyes que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. En una sociedad corporativa, que funciona efectivamente como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, el derecho, es decir, todo aquello que la ordena, es necesariamente bueno. El derecho es aquello que constituye ese cuerpo y que el juez reconoce o identifica para rehacerlo cuando se ha distorsionado. Y en ese ejercicio lo antiguo tiene una autoridad incontestable. Lo antiguo es bueno porque se encuentra más cerca de la revelación, porque proviene de un mundo que se recuerda como mejor; lo antiguo tiene autoridad y da legitimidad.

Un buen ejemplo es el arte. La tradición pictórica cristiana, una vez que se define y adopta sus rasgos propios, consiste en la repetición de imágenes que evocan a los santos, los ángeles o a Dios mismo. La técnica de los iconos bizantinos o del arte románico en la Europa latina no consiste en crear nuevas formas de representación, sino en reproducir las antiguas. En parte porque, de esa forma, se puede reconocer el motivo sea donde sea que se encuentre la obra, pero en parte también porque la representación antigua es la que da valor sagrado a la representación. Se venera la imagen misma, no solo lo que representa. Una imagen nueva, dotada con atributos diferentes, modelada por el artista en un arranque de creatividad, no es comparable en valor con aquella que encierra en sí la tradición, con aquella que evoca una imagen original, con aquella que conecta con lo sagrado. Algo similar pasa en los monasterios. Desde que en el siglo V el monacato se

Ved también

De eso hablaremos en el módulo «Lección 2: Fundamentos históricos del derecho. La Europa medieval (s. IX-XV)».

extendiera por la Europa latina bajo el signo de la regla de san Benito, una de las tareas de los monjes consistió en copiar los antiguos textos, salvarlos de la ruina del tiempo, copiar tantas veces el mismo texto como fuera posible. Por supuesto que se escribieron obras. Hubo autores prolíficos como san Isidoro de Sevilla. Pero el texto copiado tiene un valor que supera a la obra nueva, es antiguo y eso le da legitimidad. Por eso los autores nuevos no se desprenden de la tradición, sino que buscan permanentemente refugio y fundamento en ella.

Por eso debemos caracterizar al derecho de esta época como un **derecho consuetudinario** en su mayor parte. Las costumbres de dichas sociedades no nacen de la nada, sino que en buena medida son costumbres que provienen del derecho romano practicado por la mayoría de la población, también por algunas costumbres germánicas que se incorporan al acervo cristiano y, por cierto, por algunas costumbres impulsadas por la nueva situación económica y social.

Por lo demás, es la costumbre el único modo, parsimonioso y casi imperceptible de adaptar el derecho a las nuevas necesidades. Era ese el papel que correspondía a los juristas en el Imperio: ellos daban la flexibilidad y adaptaban el derecho escrito a la realidad de cada momento. Desaparecida la ciencia jurídica, son los propios hechos los que dan contenido al derecho y consiguen esa armonía.

Si cabe algún papel fundamental respecto del derecho al rey o a la autoridad política en general es el de certificar, declarar o discernir cuál es ese derecho que preexiste. Por eso, en estas sociedades, el rey, antes que legislador, es juez; y la ley, a su vez y en buena medida, tiene una función similar a la de una sentencia. Pues si algo caracteriza a los gobernantes y a los jefes de esta época, sea un simple señor o un rey poderoso, es que su principal labor es ser jueces entre aquellos que están sometidos a su poder. No son los únicos jueces, pero ser juez, descubrir el derecho, es la carga de cualquiera que se alce por encima de los demás.

Los reyes no obstante fueron también continuadores de la tradición romana tardoimperial de legislar; hasta entonces, los pueblos germanos se habían valido de un derecho totalmente consuetudinario. Esas leyes se plantearon y hasta cierto punto efectivamente lo fueron, como un receptáculo de las costumbres. Por ende, son certificadoras del derecho. Si bien es cierto que mucha de la legislación de los reinos romano-germánicos era fruto de pactos entre los nobles, el rey, la Iglesia y otros poderes, se presentaba según este relato que inserta la ley en el orden cósmico del que el derecho es reflejo.

Por eso el derecho escrito, que si bien no constituye la mayor expresión del derecho de esta época, pues esa expresión es la costumbre, es una fuente de autoridad y se entiende parte de ese derecho que es antiguo y bueno. Como se ha apuntado, en los textos se recogen costumbres germánicas y también preceptos y costumbres cristianas, pero su principal contenido está dado por el inmenso legado de los textos jurídicos romanos. No obstante, era neces-

rio que esos nuevos textos contuvieran reglas prácticas, que se ajustasen a esa nueva realidad. Mucho de lo que hay en los textos de derecho antiguo resultaba innecesario e incluso incomprensible. Por eso, y también por la dificultad técnica que por esta época supone la reproducción bibliográfica, tanto en Oriente como en Occidente los textos que circulan son breviaros, epítomes, sumas extraídas de esos textos antiguos. En efecto, los *iura*, pero sobre todo las *leges*, subsisten así, reducidos, mutilados muchas veces, pero prácticos, útiles para esa nueva realidad. Así pues, el derecho escrito que circula por la Europa latina en esta época es un derecho que recoge del antiguo las partes que le son más fructíferas y también las costumbres que se van presentando. La Europa latina es un territorio fragmentado, es cierto, pero tiene un espíritu jurídico común que viene dado precisamente por la costumbre que muchas veces tiene origen en ese pasado esplendoroso y común a todos esos pueblos como fue el del Imperio, y también por los textos que circulan que, si bien son diferentes en cada uno de los pueblos, también tienen su fuente principal en ese derecho.

De modo que, después del desmembramiento del Imperio, en territorios occidentales vemos circular cuerpos de leyes que denominamos **textos de derecho romano-germánico**, pues son promulgados por las élites germánicas gobernantes pero tienen su base en el derecho romano.

Se pueden mencionar algunos a título de ejemplo: *Lex franca Sállica* (siglo V), *Lex Ribuarria* (siglo VI), *Lex burgundionum* (siglo V), *El edicto de Rotario* (siglo VII), *Lex Baiuvariorum* (siglo VIII). El más célebre es, por su calidad e influencia, el *Breviario de Alarico* (506 d. C.) basado en gran medida en el Código Teodosiano. En la península itálica, por su especial cercanía y su parcial vinculación política con el constantinopolitano centro del mundo mediterráneo, circulan además sumas y epítomes de novelas de emperadores, sobre todo de Justiniano.

En suma, por esta época hacía tiempo que la recopilación había sustituido en buena medida a la creación jurídica de los especialistas y, tal como venimos afirmando, la actividad de los juristas como un grupo social y como sostenedores de una disciplina singular decae y acaba por prácticamente desaparecer. Esto sucede primero en Occidente y luego en Oriente, de modo que el derecho escrito se reduce a la certificación de ese otro derecho mucho más importante contenido en la costumbre o a la conservación de las pocas partes de legislación imperial o de jurisprudencia que pueden ser útiles. El derecho consuetudinario reina en dicho período en el escenario de la villa, que es, como ya hemos señalado, el contexto por excelencia de las relaciones sociales altomedievales en el Oriente y Occidente cristiano.

El legislador (sea el emperador, un rey u otra autoridad civil o eclesiástica), cuando interviene en esa realidad, lo hace precisamente para intentar ordenar aquellas cuestiones urgentes, imprescindibles, prioritarias para el mantenimiento de la vida en común en un mundo donde las relaciones comerciales han decaído y se ha simplificado la actividad jurídica. Esas áreas son por excelencia el derecho de familia y el derecho penal.

No es extraño que así sea; el resto de las cuestiones jurídicas o bien son resueltas por la costumbre o bien ni siquiera se presentan. Es el caso de muchas instituciones pensadas para un mundo sofisticado, en el que existe un aparato político universal eficaz y en el que las relaciones comerciales, políticas y civiles entre distintos pueblos se encuentran activas.

De modo que el derecho también opera con la lógica de la nostalgia. Esta palabra viene del griego y está formada por dos partes: *recuerdo* y *dolor*. La *nostalgia* es ese recuerdo que viene a la mente cuando se siente dolor.

Por eso hablamos de la **edad de la nostalgia**, pues durante la Alta Edad Media (y mucho después todavía) el recuerdo del pasado imperial persiste como paradigma de un tiempo de orden y esplendor. Así, el derecho es bueno y lo que señala esa bondad, lo que permite descubrir qué es derecho y darle legitimidad, es que sea antiguo, y en tanto que antiguo es bueno.

Es la mecánica del derecho consuetudinario: mientras más antiguo más legítimo, más fuerza y autoridad tiene. Igual que los monjes copiando antiguos escritos o que los iconógrafos repitiendo una y otra vez los motivos que conectan con el más allá, quien descubre el derecho debe buscarlo en la tradición, en la naturaleza de las cosas y en los designios de Dios. Porque, en definitiva, tanto la sabiduría antigua como el arte, la organización de la sociedad y el derecho son expresiones de una organización cósmica que es dotada de sentido por el cristianismo. De ahí que el derecho de esta época no pueda ser considerado como una creación humana, una especulación racional de un legislador, ni una regla que fuerce a ordenar la realidad de una forma distinta de la que está ordenada.

Cuando en el Imperio Romano de Oriente se produzca el renacimiento de los estudios de derecho en el siglo IX y cuando ese mismo fenómeno se dé en la Europa Latina a partir del siglo XI⁸, solo es posible explicar el fenómeno si se tiene en cuenta esta tremenda autoridad que emanaba de los textos de derecho antiguo. Las necesidades prácticas impulsarán la búsqueda de nuevas soluciones jurídicas; dichas soluciones se hallarán en los textos, en el lenguaje del derecho romano, y esos textos estarán provistos de una legitimidad uni-

⁽⁸⁾ Sobre este tema hablaremos en el módulo «Lección 2: Fundamentos históricos del derecho. La Europa medieval (s. IX-XV)».

versal precisamente porque son antiguos. En vista de ese rescate es que podemos afirmar que la herencia del mundo antiguo, en lo que respecta al derecho, está constituida por palabras, por ese lenguaje propio que dio singularidad al derecho y que apareció en la época clásica y se conservó para su reelaboración y nueva comprensión en el siglo IX en el Imperio Romano de Oriente y desde el XI en la Europa Latina.

7. Qué fue Bizancio

Tradicionalmente, se habla de Imperio Bizantino para referirse a lo que nosotros hemos denominado Imperio Romano de Oriente. Ciertamente, resulta práctico usar tal denominación para ubicarnos geográfica y temporalmente, pues se suele usar la nomenclatura de **Imperio Bizantino** a partir de una época en que el Imperio ya no se extiende por Occidente. Sin embargo, la cronología resulta polémica. Hay quienes hablan de Imperio Bizantino desde el siglo IV d. C., quienes lo hacen desde el V, el VI e incluso el VIII. La razón de este desacuerdo es que, como todas las cronologías, esta es una ficción. Pero, además, es especialmente cuestionable porque responde a un prejuicio injustificable desde la historiografía actual.

La denominación **bizantina** es muy tardía, solo en el siglo XVI el estudioso alemán Hieronymus Wolf denominó por primera vez al Imperio de Oriente de esa forma. La denominación será asumida por la historiografía europea de la Ilustración, que veía con cierto desprecio la propia historia medieval y extendió dicho prejuicio al mismo periodo en el Imperio Romano de Oriente.

La fascinación de esos historiadores por el mundo clásico les impedía reconocer su continuidad en el Imperio Romano de Oriente. Lo cierto es que los habitantes de ese imperio siguieron llamándose a sí mismos romanos y se consideraron siempre sucesores, sin solución de continuidad, del antiguo Imperio Romano. Por ese motivo hemos mantenido esa denominación para lo que se designa normalmente con el rótulo de Imperio Bizantino. Esta decisión hace sin duda más difícil el relato que hasta aquí hemos realizado, pero nos permite llamar la atención sobre la distorsión que produce usar el otro rótulo. Queremos dejar claro, pues, que **Bizancio** no es otra cosa que el Imperio Romano y que la Europa latina es fruto del desmembramiento de la parte occidental de dicho Imperio y no de su caída.

El Imperio Romano de Oriente se caracterizó, como ya hemos señalado, por la materialización en diversos planos de las almas de los dos mundos que convivían en su tradición: el grecorromano y el cristiano. El desdoblamiento del mundo al que hacíamos mención al hablar sobre el significado del advenimiento del cristianismo en el mundo antiguo, en el Imperio se escenifica en las dos instituciones que serán sus principales pilares: la Iglesia y el Imperio. A su vez, estas instituciones rigen dos comunidades de hombres que son en realidad la misma, pues el hombre no pertenece a ninguno de los dos poderes

por entero, sino que participa de ambos. Señalamos que esto generará también una tradición jurídica dual protagonizada por el derecho imperial y el derecho canónico, por las leyes (*nomoi*, en griego) y los cánones.

El Imperio entero se sostiene sobre la figura del emperador, la influencia de las civilizaciones orientales es decisiva en esta cuestión, una influencia que ya se observa fuerte desde el siglo III d. C.

En lo demás, el Imperio es muy plural, tal como lo fue desde antiguo. Los diversos pueblos que lo habitan están unidos por el mismo derecho, la religión cristiana y la lengua griega que operó como lengua franca en el Imperio. No es extraño que así haya sido. Como ya explicamos, en el Oriente mediterráneo dicha lengua tuvo un papel protagónico desde la época alejandrina. Cuando el Imperio se dividió administrativamente en dos (y hasta en cuatro, durante algún tiempo), el griego fue la lengua vehicular más usada en la zona gobernada por Constantinopla. El derecho, ciertamente, como ya advertimos, conservó para sí la lengua latina. De hecho, como veremos, hasta Justiniano fue dicha lengua la que se usó de preferencia para el quehacer jurídico, aunque muchos textos fueran traducidos o expedidos también en griego.

Sin embargo, cuando la vertiente occidental del Imperio se desmembró, el uso del latín fue haciéndose más escaso e inútil. De modo que ya después de Justiniano todo el aparato administrativo imperial, incluida la legislación, se desenvolvió siempre en la lengua helena.

Así pues, si quisiéramos trazar las constantes del Imperio de Oriente, debemos ciertamente hacer mención a las dos ciudadanías o los dos relatos que le daban sentido: lo romano y lo cristiano, y la lengua griega. Podemos observar un ejemplo plástico de la vitalidad de estos pilares en la numismática. En el siglo IX el emperador León el Sabio acuñaba monedas con la leyenda: *Leon en theo vasileus romeon*, es decir, León, en (por gracia de) Dios, rey de los romanos.



Y esta declaración que reúne los dos relatos se hace en griego, dando así una muestra patente de la pervivencia de la idea de ciudadanía romana que podía ser declarada en una lengua no latina respecto de un imperio del cual la urbe romana hacía siglos que no formaba parte.

Si observamos ahora el desarrollo jurídico del Imperio Romano de Oriente veremos que sigue una ruta similar a la de Occidente en varios sentidos, aunque con una cronología ligeramente diferente. Para abordar el problema debemos referirnos primero a Justiniano y su obra.

7.1. La obra de Justiniano

Ya hemos apuntado que la actividad de los jurisperitos como creadores y modeladores del lenguaje jurídico y, en definitiva, como fuente animada del derecho, decae desde el siglo III d. C. El vacío dejado por los juristas es llenado por las leyes dictadas por el emperador (*leges*) y la recopilación del parecer de los juristas antiguos (*iura*). Sin embargo, la decadencia del conocimiento y el estudio del derecho no se dio por igual en todo el Imperio. La parte occidental sin duda vio apagadas las luces de los juristas mucho antes. En Oriente, en cambio, al menos dos grandes escuelas de derecho se mantenían funcionando vigorosamente en Berito y en Constantinopla. Dichas escuelas, y la existencia de juristas que orbitaban a su alrededor, mantuvieron un cierto nivel de los estudios de derecho y evitaron que la ciencia jurídica se viera absorbida por otras artes tempranamente como en Occidente.

No obstante, la época otoñal de la creación jurídica también afectaba a ese mundo romano oriental. Quizás diagnosticando esa situación, como en tantos otros asuntos de la administración imperial, el emperador Justiniano emprendió una **obra de recuperación del antiguo esplendor del Imperio**.

Dicha obra pretende conservar a la vez que reestablecer y renovar ese derecho antiguo.

No es baladí observar que incluso en la obra de Justiniano está presente la nostalgia a la que nos hemos referido. Justiniano creía que era posible recuperar esa gloria imperial; de hecho, así como se volcó en el derecho también lo hizo en una reconquista de los territorios occidentales desmembrados; Italia y también la península ibérica fueron objeto de diversas incursiones que extendieron por algunas décadas las fronteras del Imperio otra vez hasta tierras occidentales. Sin embargo, la obra de Justiniano, en prácticamente todas sus aristas, será el último esplendor del Imperio antes de la depresión de los dos siglos siguientes. Sus herederos se encontrarán con más problemas que resolver que recursos para hacerlo.

En lo que respecta a su obra jurídica, en el año 528 Justiniano encargó a una comisión, entre cuyos miembros más célebres estaban Triboniano, un importante funcionario imperial, y Teófilo, un profesor constantinopolitano, la redacción de una gran compilación de la legislación imperial que la reuniera y ordenara. De modo que este código venía a reemplazar otras colecciones que circulaban por entonces como el Código Teodosiano, el Gregoriano o el Hermogeniano que mencionamos más arriba. El contenido de este código, conocido como el **código (*codex*) de Justiniano** era, pues, de *leges*, es decir, las constituciones imperiales dictadas desde antiguo hasta la fecha.

En el año 530 Justiniano ordenó que se recopilara, ordenara y armonizara gran parte de la jurisprudencia, o sea, la opinión de los juristas, sobre todo de la época clásica. El material era inmenso y supuso una obra minuciosa que seleccionara e incluyera las opiniones más relevantes, las distribuyera por materias y las armonizara entre sí. La obra finalmente se dividió en cincuenta libros y es conocida como **Digesto** o **Pandectas**. Sin duda, es la obra más importante de todas las que forman la compilación de Justiniano, pues en ella se conservó precisamente el lenguaje del derecho y las minuciosas distinciones de sus creadores y cultores más eximios.

A estas dos grandes obras se añadió otra cuyo objetivo era la instrucción en el derecho, las **Instituciones de Justiniano**. Para ello sus redactores, el mismo Triboniano, también Teófilo y otro profesor llamado Doroteo, se valieron de las Instituciones de Gayo, una obra del siglo II d. C. cuya finalidad era precisamente la de servir como manual o texto de enseñanza del derecho.

Por último, una vez acabadas estas obras, el emperador dictó aún una gran cantidad de nuevas **leyes** o **novelas** (llamadas por eso *novellae leges*). La mayoría de las novelas se dictaron en griego, marcando así un punto de inflexión en lo que se refiere a la lengua del derecho. De modo que a las tres obras mencionadas se añaden estas disposiciones que tuvieron gran importancia en Oriente y circularon también, resumidas y traducidas al latín, en Occidente.

La obra de Justiniano fue reconocida ya en su tiempo como la cumbre de la creación jurídica. En realidad, era la cumbre del fenómeno recopilatorio que caracterizó el otoño de esa otra época de creación que le precedió.

Aun así la obra de Justiniano resuelve muchas cuestiones de su tiempo, pues si bien es clasicista, en cuanto valora y pretende conservar el derecho antiguo, es capaz de realizar igualmente algunas modificaciones necesarias a su época. Para ese propósito serán especialmente útiles sus novelas, pues en ellas el emperador aborda problemas de su tiempo, sobre todo de derecho privado. Precisamente serán dichas novelas el instrumento más útil durante los dos siglos siguientes, pues no solo fueron conocidas en el Imperio Romano, sino también, como ya señalamos, circularon por zonas de Occidente.

Todas las partes de la compilación conocida hoy como *Corpus iuris civilis*, es decir, **cuerpo de derecho civil**, tuvieron en el Imperio Romano de Oriente un papel simbólico. Fueron siempre, hasta su caída en el siglo XV, el referente máximo del derecho. Pese a dejar de ser utilizada, como veremos, por los dos siglos siguientes a la muerte de Justiniano, los emperadores tuvieron siempre en la mente la ingente obra de su predecesor; tanto, que en el siglo IX, emulándolo, otros emperadores rescatarán y harán traducir al griego parte de la compilación entendiendo que, al hacerlo, manejaban y ponían en circulación

Corpus iuris civilis

El *Corpus iuris civilis* fue denominado así en el siglo XVI cuando fue editado por completo. Sus partes son el «Digesto» o «Pandectas», las «Instituciones», el «Código de Justiniano» y las «Novelas».

la obra jurídica más formidable por entonces conocida. En Occidente su papel no será menor. Ya hemos señalado y volveremos a ello en el siguiente módulo que, si bien fue poco conocida y quedó pronto olvidada, la obra de Justiniano será recuperada cuando las condiciones sociales demanden un saber jurídico como el que contiene.

Hay que señalar, por último, que Justiniano intentó impedir que su obra fuera deformada por los propios juristas a través de sus comentarios. El emperador, sabedor de la influencia de los expertos en derecho –incluso en su época, cuando la ciencia jurídica no estaba en su esplendor–, se cuidó de señalar cómo debían estudiarse los textos, cómo debían trabajarse y cómo debían reproducirse. El emperador prohibió los comentarios que no se restringieran a explicar los términos oscuros o a traducir *kata poda*, es decir, al pie de la letra, lo que en su compilación se señalaba. Con estas proscripciones, Justiniano da cuenta de la ideología imperial frente al derecho, esa que venía fraguándose desde el siglo III y que ponía al emperador en la situación de ser el único creador del mismo.

7.2. El derecho posjustiniano

Después de Justiniano, se produce en Oriente un fenómeno similar al de la Europa latina. La unidad política no fue suficiente para afrontar la pérdida de territorios de gran riqueza en manos del islam, ni los problemas sociales y económicos que se produjeron con ocasión de dicha invasión. Tampoco favoreció a la prosperidad del Imperio la aparición de epidemias que diezmaron la población precisamente en tiempos de Justiniano. De modo que también en Oriente la presencia de la administración imperial, de la cultura y, por lo que a nosotros respecta, de la ciencia jurídica, decae. El declive de esta última era una realidad desde el siglo III, pero con Justiniano tuvo un último esplendor antes de su práctica desaparición durante los siglos VII y VIII.

Igual que en la Europa latina, el derecho se convierte en un saber meramente práctico que se confunde poco a poco con el resto de artes liberales.

La generación de juristas que sucedió a los creadores de la compilación justiniana no razona ya como aquel que elabora un lenguaje y una lógica a través de ese lenguaje. El derecho se utiliza, pero no se comprende en su profundidad. Se pierden las consecuencias y la precisión del lenguaje científico.

Esa crisis de la ciencia jurídica se incrementa en la medida que, en la búsqueda de la efectividad, los mismos prácticos fueran enseñantes de las disciplinas jurídicas y educaran a alumnos que buscaban solo esa eficacia del derecho y no su comprensión.

En Oriente, por tanto, la gran compilación llamada a regir los destinos de los romanos cayó poco a poco en desuso y en el desconocimiento no solo de la población en general, sino también de muchos juristas.

Pero, tal como sucederá en Occidente más tarde, la compilación figuró como un referente ineludible; de hecho, era tenida como el continente del derecho, o mejor dicho, de la ciencia jurídica y las leyes antiguas, de por sí valiosas, sabias y buenas.

Prueba de ello es que en el siglo VIII, en plena crisis social, política y económica, cuando se hizo necesario un texto con normas claras y asequibles, se promulgó la *Ecloga*. El nombre de este cuerpo de leyes, breve y simple al modo de las leyes que se promulgaban en la Europa latina en la misma época, es testimonio de la dependencia simbólica del derecho antiguo, en especial de todo aquel recopilado por Justiniano. La palabra *ecloga* significa ‘selección’; la *Ecloga* es, pues, una selección de las normas antiguas que resultaban más relevantes y urgentes para organizar la vida social de entonces. La similitud con las leyes romano-germánicas es notable. Por supuesto, no se presentan en la *Ecloga* las costumbres germánicas que, en mayor o menor medida, están recogidas en los cuerpos que se promulgaban en Occidente, pero las prioridades son exactamente las mismas. Los emperadores que promulgan la *Ecloga*, León III y Constantino V, su hijo, igual que Rothario entre los longobardos, dedican el primer y segundo título de la *Ecloga* a los esponsales y al matrimonio respectivamente y luego muchas otras reglas al derecho de familia y al derecho penal.

La *Ecloga* fue el principal texto jurídico de su época, una época en que se conservan muy pocos documentos, no solo jurídicos, sino de toda clase. Es sin duda un testimonio de la nostalgia por el derecho antiguo, de la legitimidad que se le reconocía. El mismo sentimiento cruza la mentalidad jurídica de toda la cristiandad, tanto la oriental como la occidental.

7.3. El renacimiento de los estudios del derecho

Así como la crisis llegó más tarde al Imperio que a la Europa latina, también acabará primero en Oriente que en Occidente. Respecto de la tradición latina señalamos normalmente el siglo XI como el punto de inflexión en la recuperación de los estudios de derecho⁹. En el Imperio de Oriente, en cambio, ese punto de inflexión es anterior y se da en el siglo IX. Es lógico que así sea, pues desde Oriente hacia Occidente también es el movimiento de la recuperación económica y demográfica, la repoblación de ciudades, la recuperación del orden político. El renacimiento de las disciplinas jurídicas como disciplinas autónomas está ligado a ese resurgimiento en los otros ámbitos, pues son esos cambios los que demandan un nuevo derecho, más técnico, más sofisticado.

⁽⁹⁾Sobre esta cuestión hablaremos en el módulo «Lección 2: Fundamentos históricos del derecho. La Europa medieval (s. IX-XV)».

Por eso la recuperación de los textos de la compilación de Justiniano que se produce en dicho siglo IX no es obra del azar, sino de la necesidad de ese derecho que no era idóneo para servir a la realidad de los siglos anteriores, pero que entonces se hacía nuevamente útil.

En la época de León VI el Sabio (siglos IX-X), continuador de la obra de su padre, Basilio, se publican los **Basílicos**, que son fundamentalmente la obra de Justiniano traducida al griego más otros textos. En esa misma época, poco antes y poco después, se publicaron diversos manuales y textos que también recuperaban ese derecho y lo renovaban hasta donde era posible. Ejemplos de ellos son *El Prochiro Nomos* y la *Eisagoge* (antes conocida como *Epanagoge*), ambas obras que recuperan el derecho justiniano para la práctica, ya son textos que sirven para la enseñanza del derecho y consulta de los jueces. El mismo emperador León el Sabio dictó múltiples novelas emulando a Justiniano.

Se trata de una época de esplendor conocida como **renacimiento macedónico**.

Pues la dinastía de emperadores es conocida con ese nombre. La dinastía macedónica (que en realidad tenía sus orígenes en Armenia y no en Macedonia) fundada por Basilio I, padre de León VI, dedicó buena parte de sus esfuerzos a la restauración del Imperio y, en especial, de las artes como el derecho. Fueron años de esplendor cultural y, por supuesto, también del cultivo de la ciencia jurídica.

A principios del segundo milenio, cuando en Bolonia, según veremos, se fraguaba el renacimiento jurídico occidental, en Constantinopla se fundaban también unos estudios de derecho. Se discute que ello llegara a suceder efectivamente o que tuviera o no gran relevancia. Lo cierto es que esa época es tal vez la del giro de los equilibrios que dejaría trunco este renacimiento en el Imperio de Oriente. La razón es que ya en el siglo XII y sobre todo el XIII es la Europa latina la que se convierte poco a poco en el centro político y económico del Mediterráneo, al menos de la cristiandad. Por su parte los turcos asechan al Imperio de Oriente y lo debilitan hasta reducirlo, poco antes de su caída en 1453, a la ciudad de Constantinopla y sus alrededores. El balance de los polos de poder y focos de cultura de la cristiandad se inclinaba a favor de Occidente.

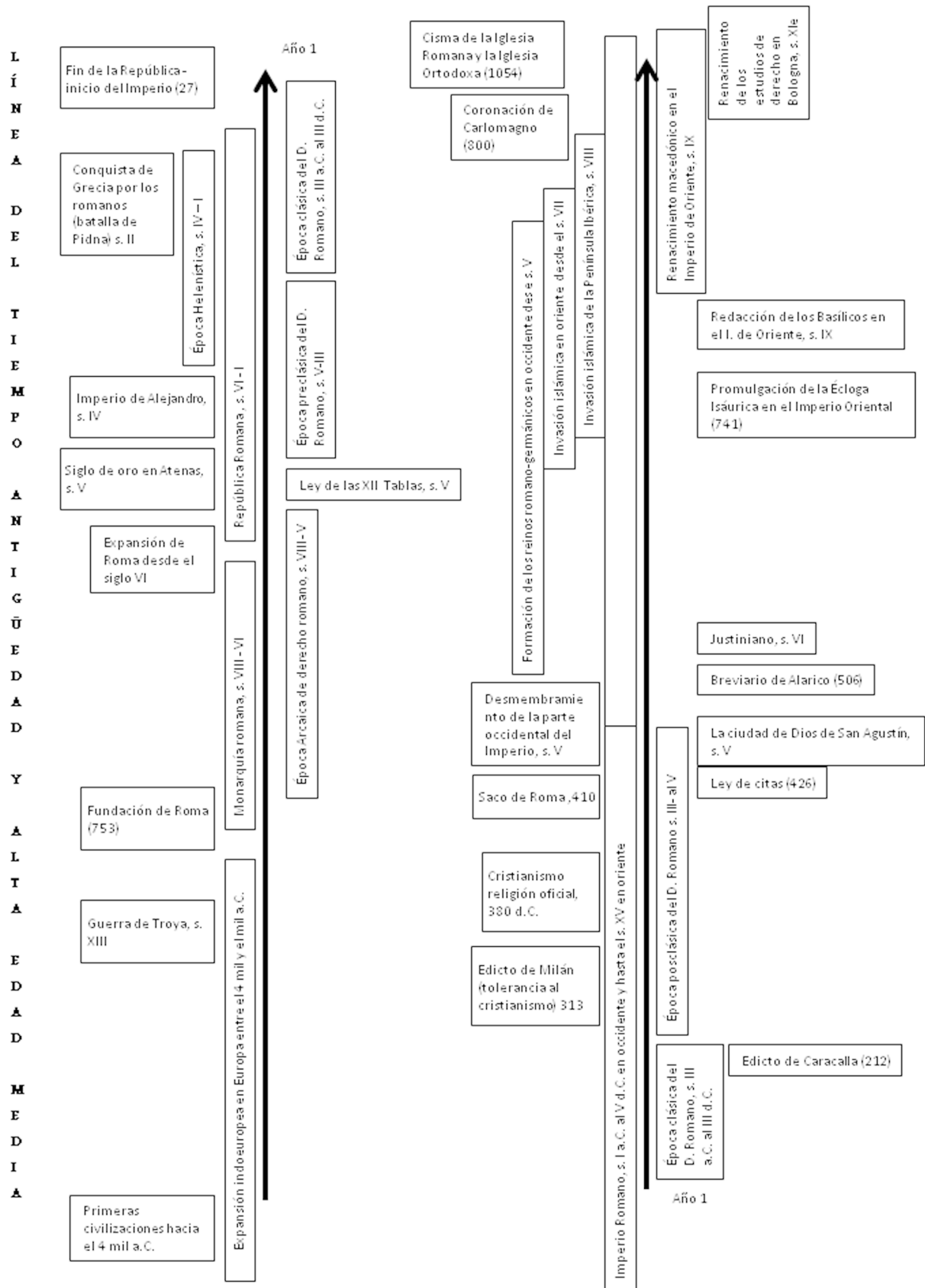
En efecto, por entonces el Imperio Romano de Oriente se hunde acosado por la guerra y la pérdida de provincias. Por ello, la dinastía Comneno (siglo XI), que sucedió a la Macedónica, tuvo su ocupación principal en la guerra. La cultura del Imperio de Oriente verá un último renacer con la dinastía Paléologo (siglo

XIII), pero el declive militar y político no se detuvo hasta la definitiva caída del Imperio en 1453. Por su parte, la Europa latina surge en todos los planos y pronto comenzará su gran expansión ultramarina.

De ahí que el renacimiento jurídico boloñés¹⁰, haya tenido una importancia fundamental para el desarrollo de la cultura jurídica europea; mientras que el renacimiento jurídico macedónico, anterior al italiano, quedó olvidado entre las ruinas del Imperio.

(10) Nos referiremos al renacimiento jurídico boloñés en el módulo «Lección 2: Fundamentos históricos del derecho. La Europa medieval (s. IX-XV)».

Por último, además de la exquisita cultura que alcanzó el Imperio de Oriente, hay que reconocer su papel en la incorporación de los pueblos eslavos a la cultura europea. Una incorporación que, por lo demás, se desarrolló en términos relativamente pacíficos a través de la evangelización y, por cierto, a través de la incorporación a la cultura jurídica romana. La Rusia de los zares, como otros pueblos eslavos, pertenecía a esa tradición, y el relato del Imperio fue resucitado por los monarcas rusos que, después de la caída de Constantinopla, vieron en Moscú la nueva Roma. Asimismo, el Imperio actuó como un muro de contención de las invasiones venidas de Oriente y África en los siglos más duros para la Europa latina.



Bibliografía

- Arangio-Ruiz, V.** (1980). *Historia del derecho romano*. Madrid.
- Barrientos Grandón, J.** (2004). *Curso de Historia del Derecho*. Santiago: Lexisnexis.
- Biondi, B.** (1953). *Il diritto romano cristiano*. Milán.
- Eliade, M.** (1985). *El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición*. Barcelona.
- Gaudemet, J.** (1958). *L'Église dans l'Empire romain* (págs. 230-240). París.
- Gaudemet, J.** (1979). *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV et V siècles*. París: Sirey.
- Gaudemet, J.** (1979). «Les transformations de la vie familiale au Bas-Empire et l'influence de Christianisme». En: *Romanitas* (núm. 5, 1962, págs. 58-85) y *Études de droit romain* (vol. III, págs. 281-310).
- Gaudemet, J.** (1982). *Institutions de l'Antiquité*. París.
- Gaudemet, J.** (1992). «La personne, droit et morale au Bas-Empire». *Droit et société aux derniers siècles de l'Empire Romain* (págs. 15-44). Nápoles.
- Grossi, P.** (1996). *El orden jurídico medieval*. Madrid.
- Guzmán Brito, A.** (1977). *La Fijación del Derecho*. Valparaíso.
- Guzmán Brito, A.** (1996). *Derecho privado romano*. Santiago de Chile.
- Haldon, J. F.** (1990). *Byzantium in the seventh century: the transformation of a culture*. Cambridge.
- Haldon, J. F.** (ed.) (2009). *The Social History of Byzantium*. Oxford.
- Kaplan, M.** (1992). *Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle*. París.
- Kaser, M.** (1979). *Storia del diritto romano*. Milán.
- Kunkel, W.** (1982). *Historia del derecho romano*. Barcelona.
- Mousourakis, G.** (2015). *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*. Suiza: Cham.
- Pérez Collados, J. M.** (2014). «El concepto de jurista y su deconstrucción durante el proceso histórico de formación del Estado». *e-SLHR* (núm. 18, págs. 1-24).
- Schulz, F.** (1968). *Storia della giurisprudenza romana*. Florencia.
- Stein, P. G.** (2001). *El derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica*. Madrid.
- Veyne, P.** (1991). *La sociedad romana*. Madrid.
- Vismara, G.** (1988). «La norma e lo spirito nella storia del diritto successorio». *Scritti di storia giuridica, 6- Le successioni ereditarie* (págs. 3-35). Milán.
- Wickham, C.** (2009). *Una nueva historia de la Alta Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800*. Barcelona.

